AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
POR
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

SUMÁRIO

I – DA LEGITIMIDADE ATIVA

II – DOS ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS

II.I – DA VIABILIDADE DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE: POLISSEMIA DA INTERPRETAÇÃO LEGAL

III – DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS (ARTS. 5º, INCISO II E LIV; 20, § 1º E 225, CF)

A) A MATRIZ CONSTITUCIONAL DOS *ROYALTIES*

B) DOS BENEFICIÁRIOS CONSTITUCIONAIS

III.I – A INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO SUPOSTO CRITÉRIO CONSTITUCIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA DO PETRÓLEO

III.II – A EFICÁCIA CONTIDA DO ART. 20, § 1º, CF, O SENTIDO DO DISPOSITIVO E A IRRADIAÇÃO DE SEUS EFEITOS AO LEGISLADOR

III.II.I – AS MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS RELATIVAS À COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ART. 20, § 1º, CF

III.II.II – DAS CONSIDERAÇÕES DO E. STF SOBRE OS *ROYALTIES* COMO COMPENSAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL

A) O CUNHO INDENIZATÓRIO DO DISPOSTO NO ART. 20, § 1º, CF

III.III – OS ELEMENTOS DE INTERPRETAÇÃO E CONCRETIZAÇÃO DO ART. 20, § 1º, CF

A) O SENTIDO DO TERMO *EXPLORAÇÃO*

B) A LITERALIDADE E UMA APROXIMAÇÃO AO ELEMENTO SISTEMÁTICO – OS BENS DA UNIÃO

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

C) A PREVISÃO DE COMPENSAÇÃO E A TELEOLOGIA DO ART. 20, § 1º, CF – A PLATAFORMA CONTINENTAL E A MAIOR LEGITIMIDADE DE RECEBIMENTO PELOS AFETADOS DO QUE PELOS CONFRONTANTES, CHAMADOS "PRODUTORES"

***C.1)* ESCORÇO HISTÓRICO – A CONTEMPLAÇÃO DOS PRODUTORES E DOS CONFRONTANTES**

C.2) A INTERAÇÃO ENTRE A LEI ANTERIOR E O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL

C.3) A SUPERFICIALIDADE DO DETERMINISMO FÍSICO E A COMPENSAÇÃO CONSTITUCIONAL POR EFETIVOS RISCOS E IMPACTOS AOS MUNICÍPIOS

D) O ELEMENTO SISTEMÁTICO EXTERNO, A TELEOLOGIA E O ÂMBITO NORMATIVO – A INDÚSTRIA PETROLÍFERA – SEU SIGNIFICADO E AS CONSEQUÊNCIAS DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE – A CONVOCAÇÃO DO ART. 225 PARA A ATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO ART. 20, § 1º, CF

D.1) O ÂMBITO NORMATIVO – A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E SUAS ESTRUTURAS

D.2) O ELEMENTO SISTEMÁTICO EXTERNO E OS IMPACTOS AMBIENTAIS

D.3) CONSEQUÊNCIAS PARA A CONCRETIZAÇÃO LEGAL DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS

D.4) DA IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DAS ATIVIDADES

III.IV – INCONSTITUCIONALIDADE: INTERPRETAÇÃO QUE EXIGE LIGAÇÃO DIRETA AO CAMPO PRODUTOR; OU COMPENSAÇÃO UNICAMENTE A QUEM FOR MAIS LIGADO À EXTRAÇÃO

IV – CONCLUSÕES

V – DA MEDIDA CAUTELAR

VI – DOS PEDIDOS

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA MINISTRA PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PARTIDO DA REPÚBLICA – PR, partido político com representação no Congresso Nacional, devidamente registrado no Egrégio Tribunal Superior Eleitoral (Resolução TSE n.º 22.504, DJ de 12.2.2007), inscrito no CNPJ sob o n.º 08.517.423/0001-95, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, na SCN Quadra 2, Ed. Liberty Mall - Torre A, salas 601/606, CEP: 70712-903, vem, respeitosamente, por seus procuradores infra-assinados, perante Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE,

com fundamento nos arts. 103, inciso VIII, 102, inciso I, alínea "a"; 5º, II e LIV; 20, § 1º; 225 da Constituição Federal, contra os arts. 48 e 49, inciso I, alínea "c" e inciso II, alínea "d", da Lei n.º 9.478/97, na redação original; arts. 48, inciso I, alínea "c" e inciso II, alínea "c" e 49, inciso II, alínea "c", da Lei n.º 9.478/97, na redação dada pela Lei n.º 12.734/2012; e 42-B, inciso I, alínea "c" e inciso II, alínea "c", da Lei n.º 12.351/10, na redação dada pela Lei n.º 12.734/2012, pelos seguintes fundamentos a seguir expostos:

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

I – DA LEGITIMIDADE ATIVA

01. A legitimidade ativa do Autor para propor a presente ação direta de inconstitucionalidade, em sede de controle concentrado, é incontroversa, eis que é partido político regularmente constituído perante o Tribunal Superior Eleitoral e com representação política no Congresso Nacional, o que o torna legitimado universal, nos termos do art. 103, inciso VIII, da Constituição Federal e art. 2º, inciso VIII, da Lei n.º 9.868/99.

II – DOS ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS

02. Os atos normativos impugnados são: art. 48; art. 49, inciso I, alínea c; art. 49, inciso II, alínea d, todos da Lei n.º 9.478/97, na redação original; arts. 48, inciso I, alínea "c" e inciso II, alínea "c" e 49, inciso II, alínea "c", da Lei n.º 9.478/97, na redação do art. 3º da Lei n.º 12.734/2012; bem como o art. 42-B, inciso I, alínea c; e inciso II, alínea c, da Lei n.º 12.351/10 (com a redação dada pelo art. 2º da Lei n.º 12.734/12), *in verbis*:

> **Lei n.º 9.478/97**
>
> Art. 48. A parcela do valor do royalty, previsto no contrato de concessão, que representar cinco por cento da produção, correspondente ao montante mínimo referido no § 1º do artigo anterior, será distribuída segundo os critérios estipulados pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989[1].

[1] **Art. 7º** O art. 27 e seus §§ 4º e 6º, da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada pelas Leis nºs 3.257, de 2 de setembro de 1957, 7.453, de 27 de dezembro de 1985, e 7.525, de 22 de julho de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação:

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

Art. 49. A parcela do valor do royalty que exceder a cinco por cento da produção terá a seguinte distribuição: (Vide Lei n.º 10.261, de 2001)

I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres:

(...)

c) sete inteiros e cinco décimos por cento aos *Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural*, na forma e critério estabelecidos pela ANP;

(...)

II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental:

d) sete inteiros e cinco décimos por cento aos *Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural*, na forma e critério estabelecidos pela ANP;

Lei n.º 12.734/2012

"Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar a compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do óleo bruto, do xisto betuminoso e do gás extraído de seus respectivos territórios, onde se fixar a lavra do petróleo ou se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou de gás natural, operados pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, obedecidos os seguintes critérios:
I - 70% (setenta por cento) aos Estados produtores;
II - 20% (vinte por cento) aos Municípios produtores;
III - 10% (dez por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural.
(...)
§ 4º É também devida a compensação financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios confrontantes, quando o óleo, o xisto betuminoso e o gás forem extraídos da plataforma continental nos mesmos 5% (cinco por cento) fixados no caput deste artigo, sendo 1,5% (um e meio por cento) aos Estados e Distrito Federal e 0,5% (meio por cento) aos Municípios onde se localizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque; 1,5% (um e meio por cento) aos Municípios produtores e suas respectivas áreas geoeconômicas; 1% (um por cento) ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e proteção das atividades econômicas das referidas áreas de 0,5% (meio por cento) para constituir um fundo especial a ser distribuído entre os Estados, Territórios e Municípios.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

Art. 3º A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, passa a vigorar com as seguintes novas redações para os arts. 48, 49 e 50, e com os seguintes novos arts. 49-A, 49-B, 49-C, 50-A, 50-B, 50-C, 50-D, 50-E e 50-F: (Promulgado em 14.03.2013)

Art. 48. A parcela do valor dos royalties, previstos no contrato de concessão, que representar 5% (cinco por cento) da produção, correspondente ao montante mínimo referido no § 1o do art. 47, será distribuída segundo os seguintes critérios:

I - quando a lavra ocorrer em terra ou em lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres:

c) 10% (dez por cento) aos Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, na forma e critérios estabelecidos pela ANP;

II - quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva:

c) 3% (três por cento) para os Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, na forma e critério estabelecidos pela ANP;

Art. 49. .....

II - .....

c) 3% (três por cento) para os Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos, na forma e critério estabelecidos pela ANP;

Lei n.º 12.351/10

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

> Art. 42-B. Os royalties devidos em função da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção serão distribuídos da seguinte forma: (Incluído pela Lei nº 12.734, de 2012)
>
> I - quando a produção ocorrer em terra, rios, lagos, ilhas lacustres ou fluviais: (Incluído pela Lei nº 12.734, de 2012)
>
> (...)
>
> c) 5% (cinco por cento) para os Municípios afetados por operações de embarque e desembarque de petróleo, gás natural e outro hidrocarboneto fluido, na forma e critérios estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); (Incluído pela Lei nº 12.734, de 2012)
>
> (...)
>
> II - quando a produção ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva: (Incluído pela Lei nº 12.734, de 2012)
>
> c) 2% (dois por cento) para os Municípios afetados por operações de embarque e desembarque de petróleo, gás natural e outro hidrocarboneto fluido, na forma e critérios estabelecidos pela ANP; (Incluído pela Lei nº 12.734, de 2012)

03. Saliente-se que os dispositivos da Lei n.º 12.351/10, alterados pela Lei n.º 12.734/2012, estão com sua eficácia suspensa, por força de decisão liminar da eminente Ministra Cármen Lúcia, na ADI n.º 4.917[2].

[2] "Pelo exposto, na esteira dos precedentes, **em face da urgência qualificada comprovada no caso, dos riscos objetivamente demonstrados da eficácia dos dispositivos e dos seus efeitos, de difícil desfazimento, defiro a medida cautelar para suspender os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49,**

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

Ainda assim, **são parte do ordenamento jurídico e podem ser igualmente apreciados pela presente ADI**, eis que a suspensão da eficácia não tem o condão de retirar a norma do ordenamento jurídico. Até que decisão definitiva seja prolatada, as referidas normas são vigentes, válidas e, portanto, passíveis de serem apreciadas em sede de controle de constitucionalidade. Por outro lado, em vista da referida decisão, estão vigentes e eficazes parte dos textos originais da Lei n.º 9.478/97, designadamente os dos seus arts. 48 e 49.

04. Corolário disso é que a liminar concedida na ADI n.º 4917 também suspendeu a eficácia do art. 48, inciso II e 49, inciso II, da Lei n.º 9.478/97, ***na redação dada pela Lei n.º 12.734/2012***, razão pela qual, em relação ao art. 48, inciso II, quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva, a parcela do valor do *royalty*, previsto no contrato de concessão, que representar cinco por cento da produção, continua sendo distribuída segundo os critérios estipulados pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, *ex vi* do disposto na **redação original** do art. 48 da Lei n.º 9.478/97. A suspensão do art. 49, II, da Lei n.º 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei n.º 12.734/2012, também repristinou a eficácia da redação original do art. 49, inciso II, da Lei n.º 9.478/97.

II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2o do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.734/2012, *ad referendum* do Plenário deste Supremo Tribunal, até o julgamento final da presente ação. Publique-se."

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

II.I – DA VIABILIDADE DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE: POLISSEMIA DA INTERPRETAÇÃO LEGAL

05. Já como decorrência dos referidos artigos 48 e 49, a ANP estabeleceu os critérios a serem adotados a partir de 1º de janeiro de 2002, para fins de distribuição do percentual de 7,5% (sete e meio por cento) sobre a parcela do valor dos *royalties* que exceder a 5% (cinco por cento) da produção de petróleo ou gás natural de cada campo, a ser efetuada aos Municípios que sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo ou gás natural. A interpretação da ANP exigiu a ligação direta ao campo produtor, para que um Município que tenha instalações de embarque e desembarque possa usufruir dos *royalties*. Dessa forma, conferiu uma determinada interpretação aos textos legais, seguida pelos órgãos administrativos e por parte do aparelho judiciário, que faz com que esses textos colidam com dispositivos e bens jurídicos constantes da Constituição, merecendo a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto.

06. Em inúmeros processos judiciais em que se discute o conceito de "afetados pelas operações de embarque e desembarque", **a ANP defende uma particular interpretação dos incisos I, alínea "c" e II, alínea "d", do art. 49 da Lei n.º 9.478/97, no sentido de ter o *poder discricionário e absoluto* de concretização normativa dos referidos dispositivos.**

07. Além disso, há uma interpretação, desenvolvida pelo STJ, a partir de razões da ANP, que considera como titulares dos *royalties* apenas os Municípios **cujas instalações estiverem predominantemente**

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

vinculadas à extração, e não à distribuição do petróleo (óleo bruto). Esses também seriam unicamente os municípios afetados por operações de embarque e desembarque de petróleo, nos termos do art. 49, e portanto os únicos beneficiários dos *royalties*. Perceba-se que, ao contrário do que uma leitura apressada poderia fazer parecer, **não se trata de pleitear uma interpretação que contemple Municípios que recebam derivados do óleo bruto e do gás natural, como a gasolina, por exemplo**.[3] Trata-se de distribuição de óleo bruto, mediante armazenamento em grandes tanques, até sua chegada às refinarias, quando aí sim transformam-se em derivados do petróleo.

08. Conforme se verá, a interpretação em torno da constitucionalidade dos dispositivos ora analisados, e, designadamente, de suas possíveis interpretações, há de ser feita em conformidade com os ditames do arts. 5º, inciso LIV; 20, § 1º e 225 da Constituição Federal.

09. Este E. Supremo Tribunal Federal adotou, em diversas oportunidades, diferentes técnicas de decisão em controle de constitucionalidade, com o intuito de dar interpretação conforme a Constituição a certos dispositivos normativos. Com o advento da Lei n.º 9.868/99, essa questão foi, enfim, pacificada, em seu art. 28.

10. Na chamada declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, o Tribunal poderá considerar inconstitucional uma hipótese de

[3] Nesse sentido, analisando de modo equivocado as ações judiciais a que se referiu, nada obstante a excelência da obra em outros aspectos, Fernando Facury Scaff. *Royalties do petróleo, minério e energia*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 296. O referido autor entendia que tais ações pleiteavam *royalties* para Municípios que lidavam com derivados do petróleo, o que não é o caso para a interpretação postulada na presente ADI, e não era o caso tratado naquelas ações, em que os Municípios prejudicados lidavam com óleo bruto ou gás natural.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

interpretação da lei, sem que haja alteração alguma no texto normativo. É exatamente o que se requer com a presente ação de controle abstrato de constitucionalidade: **impedir uma ou mais hipóteses de interpretação dos dispositivos impugnados que ignorem os condicionamentos normativos dados pelo próprio texto constitucional e por bens jurídicos fundamentais ali constantes.**

III – DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS (Arts. 5º, INCISO II E LIV; 20, § 1º e 225, CF)

A) A MATRIZ CONSTITUCIONAL DOS *ROYALTIES*

11. O art. 20, § 1º, da Constituição Federal, estabelece que a participação e a compensação financeira pela exploração de petróleo ou gás natural é um direito subjetivo dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a ser regulamentado por lei.

> "Art. 20 (...). § 1º - **É assegurada**, **NOS TERMOS DA LEI**, aos Estados, ao Distrito Federal e **aos Municípios**, bem como a órgãos da administração direta da União, **participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural**, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, **ou compensação financeira por essa exploração**.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

12. Como visto, a Constituição garante, na dicção do art. 20, § 1º, aos municípios que sofram os efeitos da exploração do petróleo, uma compensação no produto daí decorrente.[4]

13. O direito à compensação financeira (concretizado legislativamente na modalidade *royalties*) representa um direito fundamental das entidades públicas. É o que se depreende da decisão do STF no MS n.º 24.312, *que considerou os royalties receitas originárias dos entes federativos*. Trata-se de um direito de defesa, de resistência, análogo a um direito de propriedade. Não se trata, pois, de um direito a prestações.[5] Isso porque, diferentemente desses, em que a titularidade dos bens a serem adjudicados a seu titular pertence a outra esfera, no caso do direito à compensação, embora o óleo cru e o gás natural pertençam à União, parte da arrecadação decorrente da exploração do petróleo e do gás já pertence, por designação constitucional, também aos estados e municípios.[6]

14. Também de modo assemelhado ao objeto do direito de propriedade, essa participação ou compensação representa uma garantia institucional. Trata-se de proteção constitucional a instituições tidas como tão relevantes à vida estatal ou comunitária, que não podem ser suprimidas

[4] Mesmo as posições mais restritas, céticas quanto à atribuição de titularidade de direitos fundamentais a pessoas jurídicas, tendo em vista o *caput* do art. 5º (que assegura os direitos fundamentais apenas aos "brasileiros e estrangeiros residentes no país"), reconhecem que, em determinados casos, a Constituição faz referência expressa a pessoas jurídicas como titulares de direitos. Cf. Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins: *Teoria geral dos direitos fundamentais*, p. 98. Nesses casos, não há dúvida da proteção constitucional à pessoa jurídica como titular de um direito fundamental. É o que, entendemos, ocorre com o art. 20. § 1º, tratando-se aqui, evidentemente, de pessoa jurídica de direito público.

[5] Aliás, mesmo que se tratasse de direitos a prestações, eventualmente poder-se-iam também ser caracterizados como direito de propriedade. É o que ocorre com as pensões, conforme decidido pelo Tribunal Constitucional Federal da Alemanha. BVerfGE 53, 257-313, *in* Grimm/Kirchhof: *Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Studienauswahl 1*, p. 540 e ss.

[6] Portanto, poder-se-ia questionar que as riquezas do subsolo pertencem à União, e não às demais entidades federativas contempladas com os royalties. Embora isso seja correto, fato é que não pertencem a entes privados, que caracterizaria a possibilidade do tributo e, na situação ora analisada, por atribuição constitucional, situam-se já na esfera jurídica dos contemplados.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

pela via legislativa. Delas são exemplos a autonomia municipal, o princípio do juiz natural, o matrimônio, o descanso semanal remunerado, a propriedade. [7] **Os contornos desses institutos não estão completamente desenhados na Constituição; entretanto, não poderão ser definidos originariamente, por parte do legislador.**

15. Daí que a vinculação entre a lei concretizante e os dispositivos constitucionais será alta. Pode-se vislumbrar isso tanto sob o prisma da **reserva de lei qualificada**, em que o legislador está obrigado a seguir as diretivas já traçadas na Constituição; ou, por outra abordagem dogmática, em que não se pode prescindir de uma análise "tipológico-fenomenológica da atividade legiferante na definição dos interesses públicos"[8], deve-se descartar um grau de vinculatividade idêntico das leis à Constituição. Trata-se, pois, ou de uma ***competência de concretização legislativa***, em que "o legislador não 'qualifica' criativamente os interesses públicos; concretiza-os nos estreitos limites constitucionais"[9]; ou, quando muito, de uma *competência de qualificação legislativa positivamente vinculada*, em que o legislador articula e qualifica determinados interesses, porém num âmbito muito restrito: "só no caso de interesses 'absolutamente prevalecentes' da comunidade se pode, por exemplo, limitar os direitos fundamentais; não se justificando, pois,

[7] A construção é de Carl Schmitt: *Teoria de la Constitución*, p. 175-177. Não cabe espaço aqui para digressões teóricas mais aprofundadas, contudo, é necessário demarcar que Schmitt via a garantia institucional como distinta dos direitos fundamentais. E ela de fato o é. Entretanto, há de se ressaltar que, para Schmitt, direitos fundamentais eram apenas os propriamente chamados direitos de liberdade (os de primeira geração). A distinção para a concepção aqui defendida é que, em nossa visão, a garantia institucional pode ser o objeto do exercício de um efetivo direito fundamental. Vale ressaltar, porém, que o próprio Schmitt admite que "hay garantias institucionales com derechos subjectivos y sin ellos (...) pero a la esencia de la garantia institucional no le corresponde ni um derecho subjectivo, ni el mantenimiento de uma via jurídica." (p. 177) Nesse ponto, estamos de acordo com o controverso jurista alemão.
[8] Nesse sentido, J.J. Gomes Canotilho: *Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador*, p. 252.
[9] Idem, p. 252-253.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

"interesses definidos em abstracto e ao sabor das constelações políticas no poder."[10]

16. Assim sendo, **a lei deverá respeitar tanto os contornos básicos do instituto da participação ou da compensação, como também os sujeitos dela beneficiários**. Nesse sentido, poderia o legislador optar por instituir participação ou compensação, criando eventualmente algumas figuras distintas. E foi, efetivamente, o que ele fez. Basta notar a diferença entre as participações governamentais contidas na Lei n.º 9.478/97 e na Lei n.º 12.734/12: enquanto na primeira existe a figura da participação especial, na segunda foi ela excluída. **Em ambas, porém, persiste a figura dos *royalties*, enquanto compensação financeira *per se***.

B) DOS BENEFICIÁRIOS CONSTITUCIONAIS

17. Ao referir as três esferas da Federação, **o legislador não poderá deixar de contemplar aqueles municípios que efetivamente sofram os efeitos da exploração de petróleo.**

18. Assim sendo, nem poderá beneficiar igualmente todos os estados e municípios brasileiros, independentemente de serem eles afetados ou não pelas atividades de exploração de petróleo; **nem tampouco poderá excluir aqueles entes federativos que efetivamente sofrem tais efeitos, a pretexto de que não fazem parte da atividade propriamente extrativa**.

[10] Idem, p. 253-254.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

III.I – A INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO SUPOSTO CRITÉRIO CONSTITUCIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA DO PETRÓLEO

19. O suposto princípio do "equilíbrio da distribuição da riqueza relacionada à atividade petroleira", consistente em *royalties* para a extração e ICMS para o refino e distribuição de petróleo, a partir do § 1º do art. 20, em combinação com o inciso X do art. 155 da Constituição, **construído pela União e pela ANP a partir de *obiter dictum* do Min. Jobim** (aplicável, aliás, apenas às relações entre estados), foi aceito, com algumas nuances (como se verá, irrazoáveis em face do próprio critério), em acórdão que, de modo pioneiro, tratou do mérito da distribuição de *royalties*, no STJ.

20. Esse Egrégio Tribunal, até então, no julgamento de dois casos envolvendo os municípios de Paulista/PE e de Canoas/RS[11], não havia conhecido os Recursos Especiais ajuizados pela ANP, que restara vencida nas instâncias inferiores, prevalecendo então a tese de que tais municípios deveriam voltar a receber *royalties*, por se lhes haver reconhecido a existência de instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural em seus territórios.

21. Ocorre que, no RESP 1.119.643 (atualmente suspenso em vista de liminar concedida em Reclamação ajuizada perante o STF), a eminente Ministra Eliana Calmon adotou a tese da ANP, no sentido da existência de um princípio constitucional da distribuição da riqueza do petróleo, que

[11] Canoas: REsp nº 1.103.921-RS; Paulista: REsp nº 1.089.319 – PE.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

consistiria no pagamento de *royalties* para as instalações de embarque e desembarque voltadas direta e primariamente à atividade de extração do petróleo; e ICMS para as instalações voltadas direta e primariamente às atividades de distribuição e refino de petróleo.

22. A ementa do acórdão, na parte pertinente à análise da legislação cuja constitucionalidade ora se discute, está assim redigida:

> "ADMINISTRATIVO – PETRÓLEO – ROYALTIES – ICMS – ATIVIDADES DE EXTRAÇÃO E DE REFINO E DISTRIBUIÇÃO – COMPETÊNCIA DA ANP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO – DECRETO 01/91 – LEI 9.478/97 – DESTINAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
> (...)
> 2. Agência Nacional do Petróleo - ANP é competente para regular as atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo (art. 8º da Lei 9.478/97) e estabelecer critérios para o pagamento de *royalties* . (art. 49, I, c, da Lei 9.478/97).
> (...)
> 5. As instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto estão arroladas no parágrafo único do art. 19 do Decreto 01/91, as quais não incluem parque de tancagem para armazenamento de petróleo, parque de bombas e transferência de petróleo, casa de bombas de combate a incêndio.
> **6. O critério a ser atendido para o pagamento dos royalties é o da destinação dos equipamentos, os quais devem ser direta e primariamente voltados à extração do petróleo, e não à distribuição e refino.**
> **7. O equilíbrio da distribuição entre os Municípios da riqueza relacionada à atividade petroleira é feito com a distribuição de royalties (diretamente ligadas à extração do petróleo) e com o**

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

> **recebimento do ICMS (demais atividades relacionadas).**
> 8. Recurso da UNIÃO parcialmente provido e recurso da ANP provido". (STJ, Recurso Especial n.º 1.119.643, Ministra Relatora Eliana Calmon, julgamento em 20.04.2010, publicação em 17.08.2010)

23. No voto-vista de tal acórdão, ratificando as conclusões do voto da Ministra-Relatora, o Min. Castro Meira fez expressa menção ao art. 20, § 1º, da Constituição Federal, cujo teor seria justamente a base para uma interpretação mais restrita do art. 48, da Lei n.º 9.478/97, que permitiria então considerar como aptas aos *royalties* apenas as instalações voltadas direta e primariamente à extração do petróleo. Veja-se trecho significativo do voto-vista:

> **Assinale-se que essa interpretação acha-se em conformidade com o disposto no art. 20, § 1º, da Carta Magna** ("*É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração*"), que, funcionando como fundamento de validade para todas as normas que disciplinam a matéria, determina o pagamento de *royalties* aos entes federados em cujo território sejam promovidas atividades relacionadas à exploração de petróleo. (gn)

24. Desde logo, cabe uma crítica à coerência do argumento. É que do suposto princípio constitucional da repartição da riqueza do petróleo,

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

consistente em *royalties* e ICMS, decorreria, como dito, a estipulação de critérios: *royalties* para os Municípios ligados à extração; e ICMS para os ligados à distribuição de petróleo, onde se encontrariam as atividades de transporte. ***Ocorre que a própria ANP paga royalties aos portadores de instalações de embarque e desembarque e aos por elas afetados, sendo que tais municípios encontram-se já num momento francamente posterior ao da extração de petróleo***. **Assim, foi necessário o próprio estiolamento do critério: os *royalties* devem ser distribuídos não apenas aos produtores propriamente ditos, mas também àqueles portadores de instalações que seriam então *"primariamente"* ligados à extração; aos demais, caberia o produto do ICMS. Esse critério – a ser considerado decerto para uma rediscussão do nosso pacto federativo-tributário, *mas apenas para as relações entre os estados*** – é tão inusitado que, **mesmo se aplicável aos municípios, teria ainda de considerar que beneficiários de ICMS[12] são apenas as refinarias**.

25. Daí se vê que, ao aplicar tal critério, o voto-vista deixou de seguir a própria interpretação restritiva que dá ao art. 20, § 1º, CF[13], pois coerente seria então que apenas os supostos produtores (confrontantes) fossem aquinhoados com a distribuição dos *royalties*.

26. Importa referir que esse acórdão teve seus efeitos suspensos, em vista de liminar concedida na Reclamação n.º 10.958, ajuizada perante o STF. É que o reclamante, Município de Osório, entendeu haver uma declaração *escamoteada* de inconstitucionalidade na referida decisão, com o que se

[12] De parte significativa dos 25% do produto do ICMS que retorna aos Municípios.
[13] Perceba-se que a Reclamação não discute o acerto ou não da suposta interpretação com base na Constituição. Cabe apontar, contudo, a necessidade de que tal construção, para sobreviver, requer ainda o afastamento da ideia de uma interpretação sistemática entre o art. 20, § 1º e as possibilidades de compensação por dano ambiental, situadas igualmente no nível constitucional.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

ofenderia a cláusula de reserva de plenário. Assim dispôs o despacho da Ministra Ellen Gracie:

> "O Acórdão impugnado na presente reclamação, na dificuldade que teve de encontrar, na lei, definição categórica do que deva ser entendido como 'instalações terrestres de embarque e desembarque de óleo bruto ou de gás natural' ou como 'estações terrestres coletoras de campos produtores e de transferência de óleo bruto ou de gás natural' , parece, a princípio, ter lançado mão de critério inovador, **de matriz constitucional**, que importou, no mínimo, na parcial declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, de um sentido mais literal e extensivo da norma legal, adotado pela própria Administração Pública por pelo menos uma década. "(gn) (STF, Reclamação n.º 10.958, Ministra Relatora Rosa Weber, decisão proferida em 21.12.2010, publicação em 01.02.2011)

27. **A presente ADI justifica-se, pois, a par da promoção do controle abstrato em si, pela existência de uma interpretação ora adotada por alguns tribunais brasileiros, que desconsidera a exigência constitucional de compensação para muitos municípios sujeitos aos efeitos da atividade de exploração do petróleo.**

28. A interpretação da 2ª Turma do STJ pautou-se por indevida compreensão e aplicação de um *obiter dictum* por ocasião do julgamento do MS n.º 24.312 que, como já referido, reconheceu a natureza federativa da distribuição dos *royalties*. Nessa ocasião, assim se manifestou o Min. Nelson Jobim:

> *"Daí porque preciso ler o § 1º do art. 20, em combinação com o inciso X do art. 155, ambos da*

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

> *Constituição Federal. O que se fez? Estabeleceu-se que o ICMS não incidiria sobre operações que se destinassem a outros estados – petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos e derivados e energia elétrica -, ou seja, tirou-se da origem a incidência do ICMS. (...Assim, decidiu-se da seguinte forma: tira-se o ICMS da origem e se dá aos estados uma compensação financeira pela perda dessa receita. Aí criou-se o § 1º do art. 20 (...).”*[14]

29. Trata-se aqui da aplicação do chamado elemento genético de interpretação. Segundo o relato do Min. Jobim, uma melhor distribuição da renda entre os Estados teve papel importante na definição e criação do art. 20, § 1º, CF.

30. Perceba-se, porém, que a manifestação do Min. Jobim refere-se à natureza federativa das participações governamentais. É pertinente, pois, ao que estava sendo discutido naquele caso concreto. O mandado de segurança em apreço tratava justamente da possibilidade de fiscalização, pelo Tribunal de Contas da União, da aplicação dos recursos respeitantes aos *royalties*. **Não se tratava de verificar quais estados ou municípios deveriam ser enquadrados no rol dos recebedores**.

31. Além disso, **o aspecto da distribuição do ICMS tem um alcance que se limita às relações entre os Estados**. De resto, é o que expressamente determina o dispositivo constitucional com auxílio do qual se busca justificar esse suposto critério (art. 155, § 2º, X, *b*)[15].

[14] STF, MS 24312/DF, Rel. Min. Ellen Gracie (trecho do voto do Min. Nelson Jobim), DJ 19.12.2003.
[15] Art. 155 (...)
§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
X – não incidirá:
(...)

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

32. Note-se, ainda, que a chamada interpretação "genética" não congela nem esgota as possibilidades hermenêuticas do texto a ser interpretado. É lugar comum na hermenêutica o papel de destaque que cabe ao elemento teleológico e à chamada interpretação sistemática. O texto traz várias possibilidades, e aquilo que foi eventualmente "pensado" pelo Constituinte não esgota o campo de concretização administrativa e jurisdicional dos dispositivos constitucionais. Veja-se a lição do Min. Gilmar Mendes e de Paulo Branco acerca dos elementos histórico e genético:

> "Cogita-se, ainda, de analisar o processo da criação da norma, quando se investigam os antecedentes históricos, os trabalhos legislativos preparatórios que redundaram no dispositivo (interpretação histórica e/ou genética). **Esse método tende, na generalidade dos casos, a oferecer relevância mais restrita, recomendando-se, em caso de divergência, a preferência pelo sentido que se possa extrair como objetivado no preceito**."[16] (grifos nossos)

33. Ora, o art. 20, § 1º, CF, tem um alcance que transcende o eventual "pensamento" do Constituinte quando da busca do equilíbrio entre os Estados.

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;

[16] Curso de direito constitucional, 6ª ed., p. 96.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

III.II – A EFICÁCIA CONTIDA DO ART. 20, § 1º, CF, O SENTIDO DO DISPOSITIVO E A IRRADIAÇÃO DE SEUS EFEITOS AO LEGISLADOR

34. Como visto, os arts. 48 e 49 da Lei n.º 9.478/97, os arts. 48 e 49 na redação da Lei n.º 12.734/2012 e o art. 42-B da Lei n.º 12.351/10, concretizam a Constituição Federal ao fixar o direito dos Municípios aos *royalties*, nos termos dos arts. 20, § 1º e 225 da CF. Importa, assim, aclarar o alcance e o sentido de referido dispositivo constitucional. Tal empreendimento é necessário, em vista da obrigatoriedade de uma adequação material de todo o ordenamento infraconstitucional relativamente aos ditames constitucionais.

35. Há importante precedente, advindo do E. Superior Tribunal de Justiça, que, sem tratar especificamente da compreensão do referido dispositivo constitucional, **afirma sua força normativa perante a ulterior atividade legislativa.** Trata-se de decisão no Recurso Especial n.º 990.695 – ES, em voto do Ministro José Delgado:

> "Na mesma linha de entendimento, tudo a merecer meu apoio, as razões do voto de fls. 156⁄163:
> **O grande debate no caso dos autos é saber se a municipalidade tem ou não direito ao recebimento dos royalties. E, o embate jurídico que se vê, até o presente momento, cinge-se basicamente em saber qual dos dispositivos legais é que determinará se o ente municipal terá sua pretensão acolhida.**
> Em breve síntese, de um lado o autor calca sua pretensão com base no artigo 48 da Lei n° 9.478⁄97 c⁄c os critérios de distribuição dos royalties previstos na Lei n° 7.990⁄89. Do outro, posiciona-se o Estado

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

do Espírito Santo, afirmando que inexiste o direito à compensação financeira por parte do município, já que o artigo 83 da Lei 9.478⁄97 revogou expressamente a Lei n° 7.990⁄89, o que, por via oblíqua, impede a formação do direito da municipalidade.

A meu sentir, o caminho a ser trilhado, para saber se realmente o direito à compensação financeira pertence ou não ao município "canela verde", tem como ponto de partida o texto constitucional, para que, ao final, tenhamos como ponto de chegada os dispositivos conflitantes da Lei n° 9.478⁄97. Por outro giro, o primeiro campo de batalha é constitucional, para que, então, superado este, possamos partir para o segundo, que é a Lei n° 9.748⁄97, onde há o conflito real entre os artigos 48 e 83 desta lei.

Nobres pares, dentre as várias características que a Constituição Federal possui, sobreleva-se, no caso dos autos, sua feição analítica. Em razão dela, o legislador constitucional esmiuça assuntos que são, do ponto de vista jurídico, político ou social, de extremo interesse estatal.

E, em última análise, o fato do legislador constitucional descer a minúcias em assuntos como os direitos e garantias individuais do cidadão, a organização do estado e o sistema tributário e orçamentário, existe para que excessos ou omissões não sejam cometidos por aqueles que estão, de uma forma ou de outra, a frente da máquina estatal. Desse modo, preserva-se interesses ligados tanto ao poder público como ao particular.

No título III, capítulo I do texto constitucional, o legislador constitucional assegura aos integrantes do sistema federativo a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural ou a compensação financeira por essa exploração (royalties).

Portanto, surge a garantia de que, tanto para os municípios como para os Estados-membros, é resguardado quinhão da exploração do petróleo

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6° andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

ou gás natural, seja através da participação direta no resultado da exploração de tais recursos ou por via indireta, o que se dá por meio da compensação financeira.

Um ponto deve ficar claro. Malgrado a norma contida no § 1º do artigo 20 do texto maior possua natureza jurídica de norma constitucional de eficácia limitada, suas entrelinhas trazem comando imperativo negativo para o legislador infraconstitucional, haja vista que impede a formação de qualquer barreira quanto ao direito de participação dos entes estatais no resultado da exploração destes recursos naturais.

Em outras palavras, muito embora o direito a participação do resultado da exploração do petróleo/gás natural ou aos royalties deva ser (ainda que de uma forma limitada) delineado pelo legislador infra-constitucional, o mapeamento deste direito não pode chegar ao ponto de ser tolhido, restringido, minorado pelas disposições normativas da lei infraconstitucional. É que qualquer norma constitucional (mesmo de eficácia limitada), possui um mínimo de eficácia jurídica, o que impede que os comandos emergentes de qualquer texto abaixo do plano constitucional, de uma forma ou de outra, embaracem (mesmo que de forma velada) o fim colimado pelo legislador constitucional.

No caso dos autos, é notório que o objetivo proposto pelo texto constitucional é resguardar, em sua totalidade, o direito não apenas dos estados-membros na participação da exploração do resultado destes recursos naturais, mas também das municipalidades.

Assim, qualquer disposição normativa infraconstitucional que traga prejuízos à participação direta ou indireta destes recursos, não deve prosperar, sob pena da eficácia jurídica da norma constitucional cair por terra.

(...)

E, não refoge a esta regra a situação posta em julgamento, já que a determinação do legislador

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

constitucional é que seja ASSEGURADA a participação dos municípios, de uma forma ou de outra, na exploração do petróleo e gás natural, o que impede que seja inibida ou restringida pelo legislador infraconstitucional.

Ora, não há qualquer vontade permissiva no texto constitucional que acene pela possibilidade de tolhimento deste benefício entregue nas mãos dos entes municipais. Em outras palavras, para que qualquer minoração da regra contida no § 1° do artigo 20 da CF fosse possível, ou esta norma seria de eficácia restringível ou contida, ou o legislador constitucional consignasse, expressamente, no texto constitucional originário a restrição ao direito de participação dos municípios; como se vê, por exemplo, com a permissão constitucional de que a União, no campo tributário, isente mercadorias e serviços destinados ao exterior, respectivamente, do ICMS e ISS. E, nobres julgadores, em nenhuma dessas situações amolda-se o pleito requerido pelo ente municipal.

Ou atentamos para o princípio da máxima efetividade ou eficiência das normas constitucionais, que determina que a uma norma localizada no texto maior seja imprimido o sentido que lhe dê maior eficácia, portanto, que seja assegurado ao município o exercício de seu direito sem a restrição que vem sofrendo, ou se imprima maior valor normativo a uma DÚVIDA localizada na interpretação de artigos da Lei n° 9.478⁄97, quanto ao caminho que deve ser tomado no caso dos autos!

Contudo, advirta-se! Focar o olhar para esta segunda opção, certamente é afirmar que a norma constitucional contida no artigo 20, § 1° da CF está tendo sua aplicabilidade diminuída ou suprimida.

Ademais, cite-se ainda que o princípio da justeza ou conformidade funcional impõe a esta casa uma posição: Que evite qualquer subversão ou perturbação do esquema estabelecido originalmente pelo legislador constitucional originário.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6° andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

E, diante deste comando lanço a seguinte indagação: Tolher o direito de participação do município requerente, sem que haja qualquer permissão constitucional neste sentido, é prestigiar o princípio do pacto federativo, que, em última análise, refuta qualquer tratamento que implique no tratamento desigual dos seus pactuantes???? É certo que não!

.....

E, na situação posta em juízo, a exclusão do direito à compensação financeira dos entes municipais, certamente, implica na desestabilização política, social e enfraquecimento da unidade política, pois até o presente momento, o direito constitucionalmente assegurado à municipalidade está sendo restringido indevidamente.

.....

Por outro ângulo de análise, muito embora sustente o eminente e culto Des. Arnaldo Santos Souza a edição de diploma normativo para viabilizar a fruição do direito subjetivo pleiteado pela municipalidade, não vislumbro a necessidade da edição de diploma normativo para esse fim, isto porque tal direito, talhado expressamente no texto constitucional, encontra-se perfeitamente materializado no artigo 48 da citada lei. Assim, vincular o direito dos royalties a edição de nova lei é, em última análise, retirar do § 1º do artigo 20 da CF o grau de eficácia jurídica mínima que possui, já que a lei responsável pela regulamentação da participação no resultado da exploração direta e indireta do petróleo e gás natural é a lei n° 9.478⁄97, e não outro diploma. A edição de outro diploma normativo que trate do assunto pode ocorrer, já que é da essência do direito sua mutação ao longo dos tempos, vindo a aperfeiçoar um ou outro ponto da lei em questão; mas que o direito da municipalidade é patente e plenamente fruível, não resta a menor dúvida.

Ante o exposto, data vênia, sigo caminho diverso do percorrido pelo nobre relator e por aqueles que o acompanham, entendendo por bem julgar procedente a pretensão da municipalidade.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

É como voto". (grifos nossos)

36. Como se vê, o E. STJ tem fundamental precedente, no sentido de considerar que a legislação não pode amesquinhar aquilo que já está disposto no nível constitucional a respeito dos *royalties*. **Desta forma, a existirem diversas possibilidades interpretativas de eventual legislação infraconstitucional a regular a matéria, como no caso concreto, deve ser refutada aquela que desconsidera os condicionamentos constitucionais.**

III.II.I – AS MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS RELATIVAS À COMPENSAÇÃO PREVISTA NO ART. 20, § 1º, CF

37. Para a adequada interpretação do referido dispositivo constitucional, importa referir importantes manifestações doutrinárias. O então Procurador do Estado (hoje Ministro) do Rio de Janeiro, Luís Roberto Barroso, analisou em parecer as propostas de alterações na disciplina do pagamento dos *royalties* na forma apresentada pelas emendas parlamentares conhecidas como "Emenda Ibsen" e "Emenda Simon", que pretendiam redistribuir os *royalties* para todos os municípios brasileiros, independentemente de serem produtores ou possuírem instalações ligadas à exploração de petróleo e gás. O foco do parecer é a sustentação do ponto de vista do direito do Estado do Rio de Janeiro à participação no resultado da exploração do petróleo. Eis o que diz o eminente constitucionalista:

> "A discussão quanto à validade da orientação adotadas pelas emendas Ibsen e Simon depende, em grande medida, da adequada leitura do artigo 20, § 1º,

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

da Constituição. De forma mais concreta, trata-se de saber se o dispositivo cuida do direito dos estados e municípios afetados pelo processo de extração do petróleo de receberem royalties e participações especiais ou se o dispositivo constitucional estaria atendido uma vez que a União, por meio de lei, atribuísse a todos os estados e municípios, sem diferenciação, o direito a receber royalties e participações especiais.

(...)

Pois bem: o § 1º do artigo 20 fala em participação no resultado ou compensação financeira pela exploração de recursos no respectivo território. Na verdade, o conceito chave é o de compensação, seja pelo uso do território do estado ou do município, seja pelos danos ou ônus decorrentes da atividade. Pois bem: o que haveria pra compensar em relação a uma região não envolvida nem afetada no processo de exploração? Caso todos os estados e municípios tivessem o mesmo direito, o local da atividade seria irrelevante e o emprego da palavra compensação não teria pertinência. Vale dizer: o artigo 20, § 1º não teria sentido nem razão de existir. Regra ancestral da interpretação jurídica é a de que a norma não traz em si termos inúteis.

(...)

Em suma: **a interpretação gramatical ou semântica restringe os direitos previstos no artigo 20, § 1º aos estados e municípios cujos territórios são afetados pela exploração de petróleo ou gás natural. Trata-se de verdadeiro direito subjetivo constitucional ao recebimento de tais receitas.** A lei destinada a regulamentar o dispositivo constitucional **não pode ignorar esse sentido mínimo do texto, sob pena de nulidade.** Assim, a lei federal é necessária para detalhar a repartição dos recursos, mas deve obedecer à premissa estabelecida pela própria Constituição".[17] (grifos nossos)

[17] Parecer divulgado no site: www.conjur.com.br. Acesso em 15.7.2010.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

38. O eminente constitucionalista apresenta a conclusão inarredável a respeito da interpretação do dispositivo da Constituição:

> "Por fim, cumpre abordar a **interpretação teleológica**, que leva em conta, sobretudo, os fins visados pela norma, o valor ou bem jurídico tutelado pelo ordenamento. **Veja-se bem: o propósito subjacente ao artigo 20, § 1º, como todo modelo de pagamento de royalties, está associado a compensar estados e municípios pelos impactos ambientais e socioeconômicos causados ou potencializados pela atividade petrolífera.** Tal fim constitucional resulta frustrado pelo rateio linear do produto dos royalties, sem considerar os riscos e encargos dos estados confrontantes da exploração marítima do petróleo". (grifos nossos)

39. Na mesma linha, refere Luiz Cezar Quintans, ao interpretar o art. 20, § 1º, CF:

> "O legislador constitucional, através da norma em comento, determinou que todos participassem do resultado da exploração do petróleo e gás no Brasil ou recebessem uma compensação financeira pela sua exploração. O vocábulo ´todos´ se refere aos Estados, Distrito Federal e Municípios em seus respectivos territórios, além de órgãos da administração direta da União, quando se trata da parte marítima. **Existe, como exceção, o caso dos Municípios que possuem instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto e/ou gás natural. Mas, é caso específico para beneficiar os municípios que possuem tais instalações e não são confrontantes.** (...) Se no modelo de concessão os Estados, Distrito Federal e Municípios não participam dos resultados (como partícipes da exploração direta), vale a regra da compensação financeira, que só pode ser aplicada aos Estados e

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

> Municípios confrontantes e **especificamente aos Municípios que suportam as operações logísticas, de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, que não confrontam com o mar.** Qualquer interpretação diferente disso vai subverter a ordem Constitucional".[18] (grifos nossos)

40. A Constituição, em seu art. 20, § 1º, bem como em seu art. 225, preocupa-se em compensar **todos aqueles que sofrem os efeitos da exploração do petróleo, independentemente de suas instalações estarem ou não diretamente ligadas a um campo produtor, ou de terem mais pertinência à extração do que à distribuição do petróleo**. A noção de compensação é também uma tendência existente em nível mundial, que se refletiu no Brasil, conforme dá conta outro estudo específico sobre o tema:

> O processo de implantação da atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural, especialmente quando realizada na plataforma continental (offshore), como qualquer projeto de investimento de grande vulto, gera elevação extraordinária do nível de emprego e renda local e regional e, portanto, aumento igualmente extraordinário da demanda por serviços públicos e de infra-estrutura em geral.
> O motivo apontado acima **é reforçado por um outro objetivo que está usualmente associado à cobrança de royalties: o de indenizar ou compensar os impactos causados sobre o meio ambiente pelas atividades de mineração.** Conforme aponta Schantz Jr: Another justification sometimes offered for a royalty is that it compensates for environmental impacts. While sitespecific arrangements made for mining permits resolve the

[18] Os Royalties do Petróleo na legislação brasileira e a Emenda Ibsen, In www.netlegis.com.br.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

> more acute conflicts, royalties address the residual impacts. (…) **If directs controls exercised by the government were made more stronger, the need for the royalty to account for residual pollution would move inversely. A royalty in this case is the value of remaining environmental impacts** (Schantz Jr, 1994).19 (grifos nossos)

41. Essa última conclusão é bastante importante: ***os royalties servem à compensação de impactos ambientais residuais***. Segundo o autor referido, caso houvesse outros controles diretos, o valor dos *royalties* poderia ser menor. Contudo, não existe, na indústria do petróleo, um imposto ou contribuição específica, com finalidade parafiscal ambiental. A única existente refere-se à CIDE, mas aí não se trata mais de petróleo, e sim de seus derivados. Em vista disso, salta aos olhos, aliás, que a maioria dos estudos no Brasil que envolvem impactos e medidas ambientais referentes à indústria do petróleo acaba por ignorar que os *royalties* são também um mecanismo de compensação ambiental, em linha assemelhada à disciplina do poluidor-pagador.

42. A conclusão inafastável, portanto, é a de que **assiste o direito constitucional à compensação financeira, na exploração do petróleo/gás natural, tanto aos chamados municípios produtores, na realidade meramente confrontantes (eis que a maior parte do petróleo nacional encontra-se na plataforma continental) quanto àqueles que sofrem os efeitos, os impactos das atividades envolvendo**

[19]Serra, Rodrigo; Leal, José Agostinho. *Uma investigação sobre os critérios de repartição dos royalties petrolíferos*. *In* Piquet, Rosélia (org.). *Petróleo, Royalties e Região*. p. 168-169. Rio de Janeiro: Garamond, 2003. Vale referir que esse autor aponta, como se verá na sequência, um fundamento econômico autônomo, ligado a esses apresentados, sem necessariamente excluí-los.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

o petróleo. Vale dizer, justamente aos municípios afetados por esses efeitos.

43. Isso decorre já da Constituição, cabendo tanto ao legislador, quanto ao Executivo, respeitar, proteger e dinamizar o exercício desses direitos pelas municipalidades.

III.II.II – DAS CONSIDERAÇÕES DO E. STF SOBRE OS *ROYALTIES* COMO COMPENSAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL

A) O CUNHO INDENIZATÓRIO DO DISPOSTO NO ART. 20, § 1º, CF

44. O E. STF (Recurso Extraordinário n.º 228.800-5-DF), analisando a eficácia normativa do art. 20, § 1º, da Constituição Federal, em cotejo com a Lei n.º 7.990/89, que disciplina o pagamento de compensação financeira pela exploração de recursos minerais, pelo voto do Ministro Sepúlveda Pertence, decidiu o seguinte:

> "Tenho, no entanto, que a obrigação instituída pela L. 7.990-89 não corresponde ao modelo constitucional.
> Essa compensação financeira há de ser entendida em seu sentido vulgar de mecanismo destinado a recompor uma perda, sendo pois, essa perda, o pressuposto e a medida da obrigação do explorador.
> A que espécie de perda, porém, se refere implicitamente a Constituição?
> Não, certamente, à perda dos recursos minerais em favor do explorador, pois, nesse caso, a compensação financeira, para compensá-la efetivamente, haveria de corresponder à totalidade dos recursos minerais explorados. Em todo caso, não seria lógico

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

> compensar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios pela perda de bens que não lhes pertencem, mas exclusivamente à União.
> Com efeito, a exploração de recursos minerais e de potenciais de energia elétrica é atividade potencialmente geradora de um sem numero de problemas para os entes públicos, especialmente para os municípios onde se situam as minas e as represas. Problemas ambientais – como a remoção da cobertura vegetal do solo, poluição, inundação de extensas áreas, comprometimento da paisagem e que tais -, sociais e econômicos, advindos do crescimento da população e da demanda por serviços públicos.
> (...)
> Pois bem. Dos recursos despendidos com esses e outros efeitos da exploração é que devem ser compensadas as pessoas referidas no dispositivo.
> (...)

45. Não importa tratar aqui da questão tributária, base desse precedente, mas das considerações tecidas em torno do art. 20, § 1º, da Constituição, designadamente: a) da titularidade dos bens; b) da ênfase na teleologia do dispositivo constitucional, especialmente na noção de que a compensação serve a minorar danos ambientais, sociais ou econômicos; c) do fato do acórdão ater-se exclusivamente à lavra de recursos minerais em solo, e de uma contribuição voltada à exploração desses recursos.

46. Assim, embora referindo-se aos efeitos sobre os municípios onde efetivamente ocorre a extração de minerais – ou seja, tratando apenas da extração em terra -, o Min. Sepúlveda Pertence intui duas questões fundamentais: a) o titular dos minérios é a União, devendo mesmo assim ser indenizados os estados e municípios; b) **a compensação se dá em vista dos prejuízos ambientais, sociais e econômicos decorrentes da atividade de extração dos minérios**.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

47. Sintetizando a posição da mais alta Corte do País, manifestou-se o Min. Gilmar Mendes, no AI n.º 453.025 – AgR/DF:

> Naquele precedente (MS 24.312) também foi expressamente consignado nos votos dos Ministros Sepúlveda Pertence (inicialmente, inclusive invocando o decidido pela 1ª Turma no RE 228.800) e Nelson Jobim (posteriormente), cujos fundamentos foram incorporados pela relatora e pela integralidade do Plenário, que *a causa à compensação não é a propriedade do bem, pertencente exclusivamente à União, mas sim a sua exploração e o dano por ela causado*." (fls. 651) (gn)

48. Na mesma linha, manifestou-se a Ministra Ellen Gracie, na apreciação da ACO n.º 834:

> 5. Quando do julgamento do MS 24.312/DF, de minha relatoria, DJ 19.12.2003, o Plenário desta Suprema Corte, a unanimidade, firmou entendimento de que a compensação financeira prevista no § 1° do art. 20 da Constituição Federal possui natureza jurídica de receita constitucional originária dos entes federados. Naquela ocasião, ***considerou-se que essa receita patrimonial destina-se a recompor perdas (ambientais, sociais, econômicas, etc.), decorrentes da atividade de exploração do petróleo nos territórios dos Estados e de seus respectivos municípios***. (fls. 3-4 do Despacho) (gn)

49. Ora, os efeitos ambientais, econômicos ou sociais ocorrem **também para estados e municípios em que se dá o manejo do óleo bruto e do gás natural oriundos da plataforma continental, não estando tais efeitos, por óbvio, restritos à lavra do petróleo em terra**. E ocorrem

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

não apenas para os primeiros municípios que recebem o óleo bruto da plataforma continental, como especialmente para aqueles que o armazenam e o processam.

50. Deflui da análise doutrinária, bem como desse próprio STF, uma ênfase **na compensação como um mecanismo de recomposição de riscos e/ou danos ambientais, econômicos e sociais decorrentes das atividades envolvendo o manejo do petróleo**. É o que se aprofundará na sequencia, na exegese dos arts. 20, § 1º e 225, CF, com ênfase na razoabilidade e igualdade.

III.III – OS ELEMENTOS DE INTERPRETAÇÃO E CONCRETIZAÇÃO DO ART. 20, § 1º, CF

A) O SENTIDO DO TERMO *EXPLORAÇÃO*

51. Em artigo específico,[20] um dos signatários da presente ADI fez amplo estudo e referência ao significado do termo exploração, constante do art. 20, § 1º, da Constituição Federal. Ali concluiu-se, pelas razões abaixo expostas de modo sucinto, pela inadequação de uma interpretação restrita do termo, que abrangesse apenas os municípios em que ocorra a lavra do petróleo.

52. Inicialmente, de nada adianta recorrer à legislação subjacente para se buscar definir o significado do termo exploração. Primeiro, por metodologicamente inconstitucional o referido procedimento. **É que**

[20] Bornholdt, Rodrigo. *Royalties do petróleo e questões constitucionais*. Revista Interesse Público, 62, p. 126 e ss.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

estaríamos diante de uma interpretação conforme à lei, quando, na verdade, a lei é que se deve basear na Constituição. O termo exploração, catalogado no art. 20, § 1º, da Constituição Federal, deve ter um significado próprio, a ser concretizado pelo operador do direito na tarefa de interpretação/concretização.[21]

53. Não bastasse isso, nos termos estritamente legais, exploração confunde-se com pesquisa. Ora, a pesquisa é até mesmo anterior à extração, daí não podendo advir o pagamento de *royalties*. Portanto, se, nos termos legais, a produção (que inclui o transporte e a distribuição) é uma etapa posterior à exploração, como deixam claro os incs. XV e XIX do art. 6º da Lei n.º 9.478/97, *o termo constitucional "exploração" restaria absolutamente incompreensível, se adotada a legislação para fins de sua interpretação.*[22] *É que a restrição do termo exploração é aqui tão elástica, que desautorizaria qualquer município a receber royalties, fossem eles produtores (no sentido usual do termo) ou afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo.*

54. Além disso, é cânone da interpretação constitucional a consideração de que **seus termos são utilizados num sentido mais leigo, sem tanta precisão técnica**.[23] É o que também acontece na referência à *exploração* feita pelo § 1º do art. 20 da Constituição. Mas não é só!

[21] Adiante, a citação de Smend, aplicável também à situação acima exposta.
[22] Sem falar na confusão que se pode estabelecer também do termo produção, consoante o art. 6º, inc. XXVII da Lei n.º 9.478/97. Vê-se ali que faz parte da cadeia produtiva o sistema de produção de petróleo, que inclui a distribuição, a revenda e a estocagem, bem como o consumo de petróleo. Ou seja, tudo isso faz parte da produção de petróleo, uma das causas que autoriza o recebimento pelos Municípios.
[23] Cf., por todos, Dimoulis, Dimitri (Coord.-Geral). Dicionário Brasileiro de Direito Constitucional. Verbete: Interpretação Constitucional, p. 195 (por André Ramos Tavares). Saraiva: São Paulo, 2007.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

55. Como bem afirma Friedrich Müller, **o conceito jurídico de um termo difere do conceito técnico que ele possui em sua área do conhecimento**. Texto e contexto se confundem, e para o jurista germânico, os conceitos não poderão ser entendidos de uma maneira convencional, como simples abstrações de elementos encontráveis na realidade, mas sim diante de uma sua inevitável especificidade jurídica: os conceitos jurídicos são, sem dúvida, fórmulas redutoras, ordenadoras, referidas à realidade (*sachbezogene, ordnende Abkürzungsformeln*).[24] Não serão, porém, simples abstrações desta. Ao contextualizá-lo, dentro de um texto válido, com pretensão de normatividade, *o conceito jurídico transforma aquele conceito oriundo de outra área do conhecimento, ao mesmo tempo que com ele se relaciona.*

56. Note-se que não se está a defender um significado hermético, distinto do coloquial, do termo explorar. O significado mais adequado ao termo é comum, e nos é dado pelo *Aurélio*, em sua definição 4, do termo *explorar*:

> "Tirar partido ou proveito de; fazer produzir; desenvolver (um negócio ou indústria); empreender, cultivar: explorar uma fazenda, uma mina."[25]

57. Reitere-se aqui que o termo exploração, pois, não significa unicamente a atividade de extração de petróleo e gás, para fins de distribuição dos *royalties*. ***A exploração de petróleo e gás, para fins constitucionais, constitui atividade complexa que se inicia com a pesquisa, passa pela extração, pelas atividades de embarque e***

[24] MÜLLER, F. *Juristische Methodik*, 4 ed., p. 173.
[25] Buarque de Holanda, Aurélio. *Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa*, 2ª ed., Nova Fronteira, p. 743.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

desembarque e culmina com o processamento, quando então se transforma em outro produto, pronto para o consumo.

58. Assim, quer-se distribuir os frutos dessa exploração, que *é um conjunto encadeado de atividades, todas merecedoras dos royalties, dados seu entrelaçamento e dependência mútuas*. **A indústria do petróleo é clara em considerar encadeadas e dependentes entre si as atividades de extração e transporte do petróleo até sua chegada à refinaria**. Assim, apenas estão excluídos dos *royalties* os momentos posteriores à chegada do petróleo à refinaria, *pois que aí não mais haverá óleo bruto*, ensejador do pagamento dos *royalties*.

59. Contudo, ainda que, por si só, a noção de exploração fosse tomada de modo restrito, ela deve ser compreendida em interpretação sistemática com o restante do próprio dispositivo, de outros excertos da Constituição e, em especial, do âmbito normativo consistente nas particularidades da indústria do petróleo.

B) A LITERALIDADE E UMA APROXIMAÇÃO AO ELEMENTO SISTEMÁTICO – OS BENS DA UNIÃO

60. Quer-se nesse momento tratar: (i) da literalidade de alguns pontos do dispositivo constitucional; (ii) da compreensão da disciplina jurídica da plataforma continental, mar territorial e zona econômica exclusiva.

61. No que se refere ao item (i), perceba-se que o dispositivo constitucional assegura participação ou compensação aos estados, DF, municípios e órgãos da Administração direta da União, pela exploração

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

de petróleo e gás, "no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva".

62. Bem vistas as coisas, considerada apenas a literalidade do dispositivo (já informada, é verdade, por uma certa sistematicidade, adiante vista, no sentido da titularidade de cada bem jurídico), a hipótese que mais salta aos olhos do intérprete é a de que apenas aos órgãos da Administração direta da União estariam garantidos os pagamentos de *royalties* pela exploração no mar territorial, plataforma continental e zona econômica exclusiva. Afinal, esses bens não são o "respectivo território" de nenhum estado-membro ou município.

63. Com efeito, o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva não são território nem estadual, nem municipal. Eles são território do Estado brasileiro (art. 20, incisos V e VI), bens da União, servindo antes como manifestação assertiva da soberania do Estado nacional, tendo significativa importância econômica e geopolítica.

64. Ora, já quanto à lavra em terra, mesmo que os bens do subsolo sejam da União, fica claro que o dispositivo constitucional remete o benefício ao município em cujo território ela ocorre.

65. Sabe-se, porém, que a literalidade é apenas um limite à interpretação. Das várias hipóteses hermenêuticas, apenas estarão excluídas aquelas que em nenhum contexto sejam compatíveis com o texto constitucional.[26] E, se tornarmos mais abrangente, mais adequada e mais completa a análise

[26] Cf. Müller, Friedrich. *Juristische Methodik*, 9ª ed., p. 269 e ss.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

do próprio art. 20, § 1º, CF, veremos que outras "interpretações literais" são possíveis. Isso desde logo porque o próprio dispositivo faz a referência ao termo exploração (cuja adequação do significado amplo foi já acima tratada), bem como à noção de compensação pelo petróleo extraído da plataforma continental. Tudo o que remete à necessidade de investigação do sentido desses termos e de sua correlação recíproca. Em outras palavras, para além de várias conclusões sob o aspecto literal, a contribuição desse elemento é insuficiente para se chegar a uma noção mais aprofundada. Isso exige a presença de outros elementos de interpretação e de concretização.

66. Daí porque não se deve considerar ilegítimo o recebimento, pelos estados e municípios meramente confrontantes, dos frutos da plataforma continental.

67. Desde logo, em vista de uma peculiar força do elemento genético, consistente na referida manifestação do Min. Jobim, no sentido de permitir um melhor equilíbrio econômico-financeiro no pacto federativo. Ainda assim, porém, como visto, essa assertiva tem maior força para os estados do que para os municípios.

68. Contudo, o que legitima o percebimento de *royalties* pelos municípios é justamente a força dos elementos sistemático – informado pela noção de compensação e pela característica da afetação – e teleológico, devendo este perscrutar as características do âmbito normativo a ser desvelado quando do trabalho de concretização pelo intérprete.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

C) A PREVISÃO DE COMPENSAÇÃO E A TELEOLOGIA DO ART. 20, § 1º, CF – A PLATAFORMA CONTINENTAL E A MAIOR LEGITIMIDADE DE RECEBIMENTO PELOS AFETADOS DO QUE PELOS CONFRONTANTES, CHAMADOS "PRODUTORES"

69. Como já mencionado, o art. 20, § 1º, CF, contempla os municípios não só mediante "participação", mas também por uma *compensação*, conforme previsto na Constituição.

70. As considerações do Prof. Manoel Gonçalves Ferreira Filho estabelecem pertinente reflexão acerca da exploração na plataforma continental:

> "A norma distingue entre participação e compensação. Esta última pressupõe um 'prejuízo' decorrente da exploração. Já a participação constitui uma associação nos benefícios.
> *Compreende-se que o ente federativo que no seu território sofra a exploração seja por ela compensado, ou, até, nela tenha participação. Menos aceitável é que faça jus a uma participação quando a exploração se der na plataforma continental*, mar territorial ou zona econômica exclusiva, que não lhe integram o território. *Quanto à compensação, esta seria admissível, sob a condição do prejuízo*."[27] (grifo nosso)

71. Daí se extraem lições fundamentais. A principal delas confirma a noção de exploração como tendo um sentido amplo, compreendendo também a atividade de transporte do petróleo e gás natural. *Mesmo*

[27] *Comentários à Constituição brasileira de 1988*. v. 1, p. 154.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

dando-se a atividade na plataforma continental, deve-se compensar os municípios que padecem os efeitos da exploração do petróleo. Ora, evidentemente que essa exploração não pode coincidir com a mera extração, já que essa é feita em alto-mar. Ela apenas se justificaria quanto a plataformas situadas praticamente à beira-mar, que por si só já oferecem riscos ambientais. Porém, em geral, **a atividade passível de compensação é a de suporte logístico para o transporte, armazenamento ou beneficiamento do petróleo**.

72. Corolário disso é que, ***quanto às atividades desenvolvidas na plataforma continental, têm mais legitimidade para o recebimento os municípios portadores de instalações de embarque e desembarque de petróleo e aqueles por elas afetados, do que os meramente confrontantes, chamados também produtores***, que abocanham a imensa parte dos *royalties* distribuídos por conta da exploração do petróleo e que têm relação com a extração apenas de forma fictícia.

73. Como se sabe, são definidos como produtores, no caso da plataforma continental, os municípios com ela confrontantes (art. 49, II, alínea "d", da Lei n.º 9.478/97 e art. 49, II, alínea "b", na redação da Lei n.º 12.734/2012). Ora, **em tais municípios, *não há sequer uma gota de petróleo que seja extraída propriamente de seu território, sendo a compensação paga inicialmente em virtude de uma mera ficção geográfica***.

74. Essa ficção foi sacramentada por lei, como se verá na sequência.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

C.1) ESCORÇO HISTÓRICO – A CONTEMPLAÇÃO DOS PRODUTORES E DOS CONFRONTANTES

75. Foi apenas na legislação infraconstitucional que os municípios meramente confrontantes viram assegurado, pela literalidade dos dispositivos legais, o seu (generoso) quinhão na divisão e partilha dos *royalties*.

76. Com efeito, as Leis n.ºs 7.453/85 e 7.525/86 atribuíram o recebimento de *royalties* também aos municípios confrontantes com a plataforma continental, equiparando-os então aos municípios efetivamente produtores de petróleo em terra.[28] Veja-se a definição de confrontante dada pela Lei n.º 7.525/86:

> Art. 2º Para os efeitos da indenização calculada sobre o valor do óleo de poço ou de xisto betuminoso e do gás natural extraído da plataforma continental, consideram-se confrontantes com poços produtores os Estados, Territórios e Municípios contíguos à área marítima delimitada pelas linhas de projeção dos respectivos limites territoriais até a linha de limite da plataforma continental, onde estiverem situados os poços.

[28] O art. 1º da Lei 7453/85 deu nova redação ao art. 27, § 4º, da Lei 2004/53.
Art. 1º.....
§ 4º - É também devida a indenização aos Estados, Territórios e Municípios confrontantes, quando o óleo, o xisto betuminoso e o gás forem extraídos da plataforma continental, nos mesmos 5% (cinco por cento) fixados no *caput* deste artigo, sendo 1,5% (um e meio por cento) aos Estados e Territórios; 1,5% (um e meio por cento) aos Municípios e suas respectivas áreas geo-econômicas, 1% (um por cento) ao Ministério da Marinha, para atender aos encargos de fiscalização e proteção das atividades econômicas das referidas áreas, e 1% (um por cento) para constituir um Fundo Especial a ser distribuído entre todos os Estados, Territórios e Municípios.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

77. Isso coincidiu justamente com o incremento da produção de petróleo oriundo da plataforma continental, bem como com os ventos da redemocratização política do país, em que o federalismo e a descentralização de recursos ganharam impulso.

78. O legislador foi sensível a essa nova forma de exploração da riqueza oriunda do petróleo. E contemplou então os Municípios que, entendia, poderiam ser prejudicados pela exploração marítima do petróleo e gás. Optou pela maior destinação dos recursos aos confrontantes, em clara sintonia com um critério baseado no *determinismo físico*.[29] Porém, **mesmo quanto aos confrontantes, também manifestou a ideia de prejudicialidade aos municípios vizinhos**. Com efeito, cabe aqui uma interpretação sistemática com a própria referência, pela lei, às *áreas geoeconômicas* dos municípios produtores. Assim dispõe a lei quanto a essas áreas:

> Art. 3º A área geoeconômica de um Município confrontante será definida a partir de critérios referentes às atividades de produção de uma dada área de produção petrolífera marítima e a impactos destas atividades sobre áreas vizinhas.
> Art. 4º Os Municípios que integram tal área geoeconômica serão divididos em 3 (três) zonas, distinguindo-se 1 (uma) zona de produção principal, 1 (uma) zona de produção secundária e 1 (uma) zona limítrofe à zona de produção principal.
> § 1º Considera-se como zona de produção principal de uma dada área de produção petrolífera marítima, o Município confrontante e os Municípios onde estiverem localizadas 3 (três) ou mais instalações dos seguintes tipos:

[29] Toma-se o termo de Rodrigo Serra e Carla Patrão: *Impropriedades dos critérios de distribuição dos royalties no Brasil, in: Petróleo, Royalties e Região*, p. 201.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

> I - instalações industriais para processamento, tratamento, armazenamento e escoamento de petróleo e gás natural, excluindo os dutos;
> II - instalações relacionadas às atividades de apoio à exploração, produção e ao escoamento do petróleo e gás natural, tais como: portos, aeroportos, oficinas de manutenção e fabricação, almoxarifados, armazéns e escritórios.
> § 2º Consideram-se como zona de produção secundária os Municípios atravessados por oleodutos ou gasodutos, incluindo as respectivas estações de compressão e bombeio, ligados diretamente ao escoamento da produção, até o final do trecho que serve exclusivamente ao escoamento da produção de uma dada área de produção petrolífera marítima, ficando excluída, para fins de definição da área geoeconômica, os ramais de distribuição secundários, feitos com outras finalidades.
> § 3º Consideram-se como zona limítrofe à de produção principal os Municípios contíguos aos Municípios que a integram, bem como os Municípios que sofram as conseqüências sociais ou econômicas da produção ou exploração do petróleo ou do gás natural.

79. Note-se que a caracterização de um município como pertencente à área geoeconômica *pressupõe a presença de equipamentos em seu território ou a simples prejudicialidade em vista das atividades, caracterizando então que esses municípios devem ser afetados pelas atividades envolvendo o manejo do petróleo e gás*.

80. A contemplação aos confrontantes continuou na Lei n.º 7.990/89, bem como na Lei n.º 9.478/97. Deixa-se de fazer a elas maiores referências no momento, pois o que interessa nesse tópico específico é *a possível influência que as leis anteriores pudessem ter para a conformação final do art. 20, § 1º, no texto constitucional*.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

C.2) A INTERAÇÃO ENTRE A LEI ANTERIOR E O DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL

81. Ora, por mais que a Constituição tivesse tomado as referências então dadas pela lei para a redação do art. 20, § 1º, ***os significantes ali inseridos assumem agora outros contornos.*** Como se sabe, **a interpretação dos dispositivos constitucionais não se deve vincular aos significados legais prévios de dispositivos anteriores idênticos ou assemelhados**. Essa é a lição clássica do constitucionalista Rudolf Smend, que consolida a força da Constituição. Como elegantemente afirma o mencionado autor:

> "A Constituição não tem, absolutamente, em primeira linha, o propósito de transformar normas legais especiais em direitos fundamentais. Os direitos fundamentais não normatizam relações privadas, administrativas ou penais por ocasião do direito privado, administrativo ou penal, mas sim por ocasião da própria Constituição. Eles não perseguem as especiais finalidades técnicas daquelas áreas, mas sim o fim geral constitutivo do direito constitucional. (...) **mesmo uma regra copiada insere-se em uma outra dimensão, e numa completamente nova conexão significativa, que até então lhe era estranha, movendo-se, por conseguinte, igualmente, em uma relação incomensurável, se comparada à sua apresentação inicial, e à região técnico-jurídica, da qual se origina sua literalidade**."[30] (grifos nossos)

[30] SMEND, Rudolf.. *Das Recht der freien Meinungsäusserung, in: Staatsrechtliche Abhandlungen (und andere Aufsätze)*, p. 90-91 (tradução livre, objetivando menos a literalidade, e mais o contexto). No original: "Die Verfassung hat gar nicht in erster Linie spezialgesetzliche Normen in den Grundrechten setzen wollen. Die Grundrechte normieren privatrechtliche, verwaltungsrechtliche, strafrechtliche Verhältnisse nicht des Privatrechts, des Verwaltungsrecht, des Strafrechts, sondern der

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

82. Portanto, não há uma simples emenda, ou atualização, pela Constituição, de institutos antigos, desenvolvidos em outras áreas do Direito. Ao contrário, **a Constituição é que irradia seus novos conteúdos**. Isso vale também para a situação vertente, **que se refere a direitos de estados e municípios**.

83. Desse modo, mesmo que se desse vazão à força do elemento genético de interpretação, e que se entendesse presente o chamado critério do determinismo físico, ainda assim a noção de prejudicialidade, de impactos ambientais, está inserida também nos dispositivos legais que contemplavam os confrontantes, quando menos para a caracterização das áreas geoeconômicas. **Em outras palavras, caso se entendesse, erroneamente, dever-se tomar como referência os critérios existentes na lei anterior para a compreensão do dispositivo constitucional, mesmo aí está ínsita, a par do determinismo físico, a noção de prejudicialidade para qualquer compreensão que se venha a fazer de municípios portadores de instalações ou afetados por operações de embarque e desembarque de petróleo.**

Verfassung wegen. Sie verfolgen nicht die technischen Sonderzwecke jener einzelnen Rechtsgebiete, sondern den konsttuierenden Gesamtzweck des Verfassungsrechts. (...) der abgescriebene Satz (des Privatrechts – R.B.) rückt in eine andere Ebene und in seinem ganz neuen, ihm bisher fremden Bedeutungszusammenhang und tritt infolgedessen zugleich in ein Verhältnis eigentümlicher Inkommensurabilität zu seiner Vorlage und der technisch gemeinten Umgebung, aus der sein Wortlaut stammt."

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

C.3) A SUPERFICIALIDADE DO DETERMINISMO FÍSICO E A COMPENSAÇÃO CONSTITUCIONAL POR EFETIVOS RISCOS E IMPACTOS AOS MUNICÍPIOS

84. Na acurada análise econômica promovida por Rodrigo Serra e Carla Patrão, houve um claro determinismo físico na distribuição **legal** dos *royalties*, consistente nas "projeções marítimas dos limites municipais", alcançados pelos pares de linhas ortogonais e paralelas. Segundo os autores, essa solução não atende ao "fundamento econômico[31] para repartição dos *royalties* entre os municípios, qual seja, **de que estes recursos devam ser distribuídos sob o propósito de preparar os municípios impactados pelas atividades petrolíferas para a fase pós-esgotamento das jazidas**. Isto, obviamente, porque não há, a princípio, **qualquer relação entre a distância física que separa o poço petrolífero e o município confrontante e a intensidade da presença de capitais transitórios nos municípios beneficiários**."[32] (grifos nossos)

85. **Contudo, à guisa de concretizar os arts. 48 e 49 da Lei n.º 9.478/97, esse critério do determinismo físico foi utilizado pela ANP não**

[31] Os autores analisam, sob o prisma da teoria econômica, os fundamentos para o pagamento de royalties. Concluem, quanto a Estados e municípios que, para além da peculiaridade da questão federativa e fiscal no caso brasileiro, devem receber todos os Municípios que efetivamente sofram os efeitos da indústria petrolífera, não apenas pelos impactos que causa, e também nem só pelo incremento de infra-estrutura necessária, mas fundamentalmente porque essa infra-estrutura, em determinado momento, se tornará obsoleta, dada a finitude dos recursos (*Impropriedades dos critérios de distribuição dos royalties no Brasil, in: Petróleo, Royalties e Região,* p. 191-192). Há, pois, um peculiar mecanismo de justiça intergeracional, cujas bases estão fincadas na teoria de Hotteling. Hartwick, baseado em Hotteling (pioneiro na análise de um peculiar conceito de renda mineral. Seus estudos baseavam-se na hipótese de um explorador privado, razão pela qual sua teoria sofre ajustes quando o bem é do poder público), sustenta que "a geração atual deixe, para a futura, capital reprodutível, humano ou natural, o suficiente para que esta mantenha um padrão de vida satisfatório". Assim, "a geração atual deve converter parte da renda gerada (renda de Hottelling) pela extração de recursos não-renováveis em máquinas e trabalho... Lembrando Hotteling, se o valor do recurso é o valor futuro descontado para o presente e, uma vez aplicada a regra de Hartwick, estará preservando-se o montante total de capital." Tudo em Rodrigo Serra e Carla Patrão, *op. cit*., p. 192.

[32] Serra, Rodrigo; Patrão, Carla, *op. cit.*, p. 202-203.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

apenas para aquinhoar os confrontantes, mas também com o objetivo de definir o sentido de "instalações de embarque e desembarque de petróleo" e de municípios afetados por operações de embarque e desembarque de petróleo. Assim, em vez de limitar a utilização do critério para os confrontantes, a ANP subverteu a teleologia dos arts. 48 e 49, incrementando o determinismo físico ao exigir uma suposta ligação ao campo produtor – na plataforma continental!!! – da instalação de embarque e desembarque que recebe o petróleo dali oriundo e transportado até a costa brasileira.

86. Os autores citados, Rodrigo Serra e Carla Patrão, concluem igualmente no sentido de uma maior legitimidade, para o recebimento de *royalties*, daqueles municípios que efetivamente sofrem os impactos da exploração de petróleo:

> "Resta, assim, **como definição sensível aos efetivos impactos econômicos das atividades petrolíferas sobre o continente, o conceito de municípios onde se localizam instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque vinculados àquela indústria**."[33] (grifos nossos)

87. Perceba-se então que **o dispositivo constitucional, mediante a noção de compensação, corrobora exatamente essa necessidade de uma indenização em face de um prejuízo sofrido pelos municípios que suportam as atividades de embarque e desembarque de petróleo ou são por elas afetados**. A compensação se justifica verdadeiramente em alguns casos: **(i) quando a vocação socioeconômica do município se**

[33] *Op. cit.*, p. 203.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

altera em vista da instalação do aparato da indústria do petróleo, com todas as conseqüências daí advindas; (ii) em função de impactos ambientais e/ou paisagísticos; (iii) em vista da essencialidade das instalações localizadas nos municípios, para o adequado escoamento do petróleo e do gás natural, com eventuais riscos ambientais daí advindos. Portanto, quando verificadas ao menos uma destas condições, os municípios confrontantes se equiparam aos afetados, detendo a mesma legitimidade que estes últimos.

D) O ELEMENTO SISTEMÁTICO EXTERNO, A TELEOLOGIA E O ÂMBITO NORMATIVO – A INDÚSTRIA PETROLÍFERA – SEU SIGNIFICADO E AS CONSEQUÊNCIAS DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE – A CONVOCAÇÃO DO ART. 225 PARA A ATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO DO ART. 20, § 1º, CF

88. Se a literalidade revela as possibilidades da atividade interpretativa, e o elemento sistemático convoca a atenção para as peculiaridades do contexto em que será feita a interpretação, o elemento teleológico exige venham à luz particularidades do âmbito normativo, ou seja, daquela parcela de realidade sobre a qual incidem os elementos do texto de norma, e que com ele se confundem.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

D.1) O ÂMBITO NORMATIVO – A INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E SUAS ESTRUTURAS

89. O âmbito normativo, reitere-se, nada mais é que a parcela da realidade para a qual o texto de norma se dirige.[34]

90. Na situação em análise, cabe então indagar do sentido da indústria petrolífera em relação aos preceitos constitucionais que as abarcam.

91. Como se sabe, a indústria petrolífera destaca-se por dois aspectos: sua vitalidade enquanto matriz energética, com enorme impacto para as atividades econômicas; e pelas consequências danosas de sua atividade, em vista dos impactos ambientais e socioeconômicos dela decorrentes.

92. Basta recordar que o petróleo moveu em grande parte a geopolítica mundial, desde o início do século XX, não sendo diversa sua importância nos dias atuais. Nações e povos se emancipam, alteram seus regimes, criam e destroem Estados e ganham força e pujança em vista do desenvolvimento da indústria do petróleo.[35]

93. Em atenção a tal aspecto, a Constituição contemplou em vários dispositivos a atividade petrolífera. Considerou-a uma atividade econômica, porém, em vista de seu sentido estratégico, sujeita à

[34] Müller, Friedrich. *Juristische Methodik*, 9ª ed., p. 37. O autor destaca, porém, que se trata aqui de *uma realidade recortada já pelo texto de norma.* Para um singelo exemplo no direito brasileiro, quando a Constituição reconhece a existência da liberdade de associação para fins pacíficos, está já a excluir aquelas associações paramilitares, eventualmente encontráveis na realidade, mas não admitidas pelo direito.
[35] Cf., por todos, Daniel Yergin. *O Petróleo*. Scritta Editora, 1989.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

exploração em regime de monopólio (art. 177). Aliás, mesmo a apropriação da plataforma continental pelo Estado brasileiro teve em mira os potenciais petrolíferos ali existentes.

94. Quanto aos impactos ambientais, como se trata de indústria primariamente poluente, abarcou-a, ainda que não explicitamente, em todo o regime de cautelas e políticas de prevenção previstos no art. 225. Como se sabe, as atividades envolvendo o petróleo têm direto impacto ambiental. Em vista disso, o petróleo e o gás natural devem ser considerados também recursos minerais, conforme previsto no § 2º desse dispositivo:

> Art. 225
> (...)
> § 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

95. Sobre a qualificação jurídica do petróleo e do gás natural como recursos minerais, cabe a excelente interpretação sistemática [36] de Alexandre Monteiro (*et alli*):

> Por atividade minerária, compreende-se a movimentação dos recursos minerais contidos no solo ou subsolo, cuja finalidade precípua é o aproveitamento econômico dos referidos minerais. Num conceito científico mineral "é um elemento químico ou substancia cuja composição pode ser expressa em termos de uma fórmula química e que

[36] E novamente pertinente à citação de Müller, atrás referida, de que os conceitos assumem em direito outro significado.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

> ocorre naturalmente na Terra com estrutura cristalina definida baseada em um arranjo interno ordenado de átomos ou íons" Estão excluídos, portanto, os líquidos, gases e elementos de origem orgânica.
> Embora, todavia, as ciências exatas tenham tal entendimento, *o direito, por vezes, possui seu tratamento próprio a respeito de determinados objetos, e assim acontece no caso das atividades minerárias*.
> A Constituição Federal traz um novo conceito, que passa a ser o norteador da seara jurídica no que diz respeito às atividades de mineração, a saber: o conceito de recurso mineral. Juridicamente, recurso mineral é considerado como uma concentração de matérias-primas, seja em estado sólido, líquido ou gasoso, no interior ou sobre a costa terrestre. Tal expressão é encontrada no art. 20, inc. IX, da Carta Magna, que dispõe que são bens da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo. **Não resta dúvida que o legislador abrangeu, no conceito de recurso mineral, substâncias como o petróleo e o gás natural**. Do mesmo modo, o art. 22, inc. XII, dispõe que compete privativamente à União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia.
> (...)
> Concluímos, portanto, que **apesar de o petróleo e o gás natural não serem considerados, sob o ponto de vista geológico e cientifico, como um mineral, *o nosso ordenamento jurídico o abraça como sendo um recurso mineral* e, por isso, as atividades que digam respeito a estas substâncias fósseis serão enquadradas como minerais**.[37] (gn)

96. Além disso, **o meio ambiente degradado, quando da exploração na plataforma continental, não é somente a área respeitante aos**

[37] MONTEIRO, Alexandre Flávio Medeiros; BARROS, Felipe Maciel Pinheiro; JERÔNIMO DA SILVA, Keisson Cristiano; LEITE, Fábio Augusto de Castro Cavalcanti Montanha. Infrações Penais Ambientais Específicas: da poluição Mineral, Atmosférica, Visual, Sonora e Hídrica. Aplicação à Indústria do Petróleo e Gás Natural, in Direito Ambiental Aplicado à Indústria do Petróleo e do Gás Natural, p. 160-161.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

equipamentos situados no mar. O meio ambiente que se degrada é também e fundamentalmente aquele respeitante às áreas em que situados os equipamentos em terra, que acolhem o petróleo oriundo do mar.

97. Em vista disso, cabe referir outro elemento do âmbito normativo, crucial para a compreensão dos municípios a serem compensados. **Trata-se da *complementaridade entre as estruturas e equipamentos existentes para o recebimento do petróleo oriundo da plataforma continental***. Tudo o que implica a necessidade de que todos os municípios que contribuem com estruturas significativas para o manejo do petróleo devam receber os *royalties*. A título ilustrativo, cabe citar relevante trecho do acórdão do TRF/4ª Região, ao apreciar a Apelação Cível 2001.71.00.040286-0:

> "De outro lado a expressão "embarque e desembarque" deve ser interpretada de forma a alcançar o depósito (tancagem), porquanto ligados por oleodutos as monobóias localizadas em mar aberto na costa do Município de Tramandaí. **Acata-se aqui *a idéia de um sistema operacional unitário*. Nota-se que sem a tancagem, não é possível a operação de embarque e desembarque**. **O Município é parte integrante e inafastável da estrutura exigida ao recebimento do petróleo desembarcado.** Nem poderia ser outro entendimento, seja pela ótica da legislação de regência, seja à luz do que informa a própria Agência Nacional do Petróleo, em razão da matéria fática que a questão encerra.
> Note-se que, nos termos da Lei nº 9.478, de 06-08-1997, art. 49, inciso I, alínea C, farão jus ao recebimento dos *royalties* os municípios que "... sejam afetados pelas operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural..." (grifei).

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

Afetados, no caso e segundo Aurélio, vem a ser os que sofrem afecção, ou seja, os Municípios que por alguma forma sofrem lesão, são atingidos, prejudicados pelas operações de lavra, embarque ou desembarque de hidrocarbonetos em seu território. Tais pagamentos se constituem, indubitavelmente, em uma espécie de compensação pelos prejuízos de natureza ambiental, paisagística e urbana que instalações dessa natureza provocam naqueles territórios.

Ora, consoante documentos das fls. 306/316 da própria Agência Nacional de Petróleo, no Município de Tramandaí, estão localizadas em mar duas monobóias para operação de descarregamento de navios, de onde o produto segue para o litoral e daí, por oleoduto de 8 km, até o Terminal de Osório (Terminal Almirante Soares Dutra (fls. 312). Neste Município litorâneo, Tramandaí, portanto, o único impacto do descarregamento de petróleo e gás se limita a um oleoduto que corta parcela ínfima do seu território (menos de 8 km). Apenas isso.

Já o Município de Osório, igualmente de acordo com a ANP, por ter em seu território o Terminal Almirante Soares Dutra, "... cuja função é a de receber e transportar petróleo e derivados para a Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP)..." (fls. 313) suporta nada menos que "... 19 tanques, sendo 7 para armazenamento de petróleo (capacidade total de 503.782 m3) e 12 para derivados (capacidade total de 352.173 m3)..." contando ainda "...com uma sala de controle (que monitora todo o terminal), com um laboratório químico e com uma oficina de manutenção" (fls. 313). **Como se vê, a diferença entre o impacto causada em um e outro Município é enorme, afigurando-se absolutamente desarrazoado que se entenda que aquele que não tem uma gota sequer de petróleo transitando ou sendo manipulado em seu território – a não ser no interior de oleoduto – seja beneficiário de tais pagamentos, em detrimento do vizinho situado a menos de 10km e que recebe todo o produto**

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

> **descarregado, ao argumento que busca dissociar operações tão umbilicalmente ligadas, a saber o descarregamento dos navios para as monobóias, o transporte até o litoral e daí para a tancagem. Essa distinção, se feita em texto legislativo seria de extrema injustiça e injuridicidade, por alheio a sentido elementar de Direito, por contrário a ele; dimanando de mera norma administrativo-interpretativa é absolutamente insustentável, por dissociada de princípios de direito e justiça, não podendo por isso mesmo prosperar**." (gn)

98. Perceba-se, pois, que é através de elementos do âmbito normativo e da interpretação sistemática que ganham força, para elucidação do art. 20, § 1º, CF, **princípios como a igualdade e a razoabilidade, além dos dispositivos constitucionais respeitantes ao art. 225, particularmente no sentido de se esclarecer os beneficiários da compensação**.

D.2) O ELEMENTO SISTEMÁTICO EXTERNO E OS IMPACTOS AMBIENTAIS

99. É importante referir ainda que o Estado brasileiro, atento aos impactos ambientais da indústria do petróleo, possui vasta legislação a respeito. *Nela se destaca, mais do que a parte de produção propriamente dita, os cuidados necessários justamente com as atividades de transporte do petróleo.*

100. Assim, em concretização ao art. 20, § 1º, e ao art. 225 da Constituição, o elemento sistemático reclama ainda a *análise da legislação referente aos cuidados e perigos da atividade petrolífera enquanto uma atividade carregada de externalidades, principalmente*

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

ambientais. Perceba-se aqui que **a legislação explicita exigências já existentes no nível constitucional, designadamente na parte relativa ao meio ambiente, não se tratando, pois, de uma inusitada interpretação sistemática entre dispositivos no nível constitucional e outros em nível infraconstitucional**.

101. Nesse sentido, a Lei n.º 9.966/2000 dispõe sobre "a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional."[38]

102. Ou seja, **o próprio elemento sistemático indicia já aquilo que, de outro modo, estaria contido no âmbito normativo: *a íntima relação entre as atividades envolvendo o manejo do petróleo e as externalidades daí decorrentes, destacando-se a poluição e as consequências ambientais em geral.***

103. Estudo do *National Research Council*, dos Estados Unidos, apontou as seguintes causas da presença de óleo no mar:

> "(iii) o transporte de petróleo pode provocar escoamentos de diferentes quantidades, desde os acidentes associados a petroleiros como o Exxon Valdez, até as liberações operacionais relativamente pequenas e regulares de petroleiros, ou vazamento de oleodutos."[39]

[38] No mesmo sentido, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (10.12.1982) exige uma série de cuidados para o transporte de petróleo no mar.
[39] *Apud* Maria Augusta Paim*: O petróleo no mar: o regime das plataformas marítimas petrolíferas no direito internacional.* Rio de Janeiro: Renovar, 2011, p. 355.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

D.3) CONSEQUÊNCIAS PARA A CONCRETIZAÇÃO LEGAL DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS

104. Ora, é bem de se ver que, como bem referido pelo voto do Min. José Delgado e pela acurada análise do Prof. e Min. Luís Roberto Barroso, da exigência constitucional de compensação surge a necessidade de proteção, pela legislação, àqueles municípios afetados pelas atividades envolvendo o manejo do petróleo e do gás natural.

105. Assim, se a indústria do petróleo é altamente poluente, **devem ser contemplados com compensações aqueles municípios que correm riscos de sofrer um dano ambiental.** Trata-se, aqui, de um elemento do âmbito normativo.

106. Além disso, como já referido, a indústria do petróleo é também excludente, carregada de externalidades outras além da ambiental. Daí se conclui que **merecem compensação também todos aqueles municípios cuja vocação socioeconômica se vê ameaçada ou, no mínimo, prejudicada, em decorrência das atividades envolvendo o manejo do petróleo ou do gás natural, designadamente por se tratar de recursos que, cedo ou tarde, se exaurirão.** Trata-se de outro elemento do âmbito normativo.

D.4) DA IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DAS ATIVIDADES

107. O raciocínio completa-se a partir da *compreensão da importância estratégica das atividades*. Tanto a extração quanto o transporte e o refino do petróleo constituem *monopólio da União*. O regime de

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

monopólio constitucional envolve uma atividade econômica em sentido estrito. Trata-se de uma atividade excepcionalmente reservada à União, que pressupõe a unicidade da titularidade sobre a produção econômica.[40]

108. Portanto, também por essa visão, a tese da ANP, secundada pelo STJ, ao restringir os *royalties* à lavra no território do município, quando da exploração na plataforma continental, não tem respaldo constitucional. ***A Constituição não faz a diferenciação entre extração e transporte do óleo bruto, para fins de pagamento de royalties aos municípios. A Constituição não promove a divisão das atividades para efeitos de compensação financeira pela exploração***. Ao contrário, **a Carta Magna deliberou pelo regime de monopólio das atividades consideradas em bloco, ou seja, considerou o seu conjunto.**

III.IV – INCONSTITUCIONALIDADE: INTERPRETAÇÃO QUE EXIGE LIGAÇÃO DIRETA AO CAMPO PRODUTOR; OU COMPENSAÇÃO UNICAMENTE A QUEM FOR MAIS LIGADO À EXTRAÇÃO

109. Em vista de todo o exposto, as hipóteses de interpretação da lei que exigem, para distribuição de *royalties*: a) a ligação direta da instalação ao campo produtor; ou b) maior pertinência à extração do que à distribuição do petróleo, são inconstitucionais, **na medida em que, com essa exigência, excluem municípios portadores de instalações e/ou afetados, todos sofredores de iguais ou maiores impactos ambientais,**

[40] Conforme ainda Eros Roberto Grau: "Nesses termos, monopólio significa privilégio de ser titular do poder de relacionar-se economicamente com determinado mercado, de forma isolada e única, sem interferência de outros competidores, na venda (polein) de determinadas mercadorias, Trata-se, aqui, de monopólio de atividade econômica. Em *Elementos de Direito Econômico*. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1981, p. 85.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

socioeconômicos ou paisagísticos, do direito à compensação. **Reitere-se: esse direito à compensação é norma de índole constitucional**.

110. Portanto, tal interpretação restritiva exclui hipóteses de recebimento que tem seu fundamento já na Constituição.

111. Portanto, segundo a Constituição, **devem receber compensação financeira tanto os portadores de instalações como os municípios afetados socioeconômica, paisagística ou ambientalmente, em sentido amplo**.

112. Saliente-se ainda que os referidos critérios restritivos são completamente destituídos de razoabilidade e igualdade. Com efeito, **como se pode exigir ligação direta a um campo produtor localizado por vezes a dezenas ou a mais de uma centena de quilômetros da plataforma continental?** Nesses casos, artificialmente está-se a considerar que a ligação direta faz-se com o "primeiro ponto" de desembarque do óleo. Assim, apenas para dar um exemplo, no Rio Grande do Sul o Município de Tramandaí receberia os valores por possuir uma monobóia na qual transita o petróleo advindo da plataforma continental; enquanto o de Osório, que armazena o petróleo oriundo da monoboia, e que corre muito mais riscos ambientais, nada recebe!!!

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

IV – CONCLUSÕES

1) A presente ação pretende seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos arts. 48 e 49, I, "c" e II, "d", da Lei n.º 9.478/97, na redação original; arts. 48, I, "c", II, "c" e 49, II, "c", da Lei n.º 9.478/97, na redação dada pela Lei n.º 12.734/2012, bem como do art. 42-B, I, "c" e II, "c", da Lei n.º 12.351/10, com as alterações promovidas pela Lei n.º 12.734/12. Embora tais dispositivos da Lei n.º 12.351/10 estejam com sua eficácia suspensa, em vista de liminar concedida na ADI n.º 4917, estão vigentes e são parte do ordenamento jurídico. Por outro lado, em vista da mesma liminar, os referidos dispositivos originais da Lei n.º 9.478/97 encontram-se vigentes e eficazes, norteando o atual modo de distribuição de *royalties* pela ANP;
2) A ANP editou atos e desenvolveu uma tese, acolhida pelo STJ, no sentido de que as expressões "instalações de embarque e desembarque de óleo bruto e gás natural" são apenas aquelas que possuem ligação direta com o campo produtor, excluindo assim outras que sofram efeitos socioeconômicos, ambientais ou sejam necessárias à concretização da cadeia de produção do petróleo e do gás. Como suposto corolário disso, o STJ entendeu que apenas os municípios cujas instalações sejam ligadas predominantemente à extração, e não ao transporte e distribuição do <u>óleo bruto ou do gás natural</u>, fazem jus aos *royalties*;
3) O direito à compensação financeira (concretizado legislativamente na modalidade *royalties*) representa um direito fundamental das entidades públicas. A lei concretizante está fortemente vinculada (seja como reserva de lei qualificada, seja como competência de concretização legislativa) às hipóteses previstas no art. 20, § 1º, CF, devendo compensar os beneficiários ali previstos. Assim sendo, todos os municípios que sofram os efeitos do manejo de petróleo ou gás natural devem ser compensados, independentemente de estarem ou não vinculados à mera extração;
4) A interpretação da 2ª Turma do STJ pautou-se por indevida compreensão e aplicação de um *obiter dictum* do Min. Jobim, por ocasião do julgamento do

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

MS n.º 24.312, no sentido de que, da combinação entre o *§ 1º do art. 20 e o inciso X do art. 155 da Constituição, os royalties seriam destinados aos Estados da extração; e o ICMS aos Estados destinatários do óleo bruto ou do gás natural. Tal manifestação, porém,* refere-se à natureza federativa das participações governamentais, não tendo relação com os efeitos do manejo do petróleo e gás natural sobre as instalações de embarque e desembarque. O aspecto da distribuição do ICMS, ademais, tem um alcance que se limita às relações entre os estados. Perceba-se, ainda, que a chamada interpretação "genética" não congela nem esgota as possibilidades hermenêuticas do texto a ser interpretado. O papel de destaque na hermenêutica cabe ao elemento teleológico e à interpretação sistemática;

5) Há forte doutrina referindo o direito subjetivo constitucional dos municípios à compensação, "seja pelo uso do território do estado ou do município, **seja pelos danos ou ônus decorrentes da atividade**";

6) A conclusão inafastável é a de que **assiste o direito constitucional à compensação financeira, na exploração do petróleo/gás natural, tanto aos chamados municípios produtores, na realidade meramente confrontantes (eis que a maior parte do petróleo nacional encontra-se na plataforma continental), quanto àqueles que sofrem os efeitos, os impactos das atividades envolvendo o petróleo. Vale dizer, justamente aos municípios afetados por esses efeitos**. Portanto, **todos aqueles que sofrem os efeitos da exploração do petróleo, independentemente de suas instalações estarem ou não diretamente ligadas a um campo produtor, ou de terem mais pertinência à extração do que à distribuição do petróleo, estão aptos ao recebimento de *royalties*;**

7) O STF tem reiterada jurisprudência, relativa à lavra em terra, que enfatiza **a compensação como um mecanismo de recomposição de riscos e/ou danos ambientais, econômicos e sociais decorrentes das atividades envolvendo o manejo do petróleo**. Ora, os efeitos ambientais, econômicos ou sociais ocorrem **também para estados e municípios em que se dá o manejo do óleo bruto e do gás natural oriundos da plataforma continental**, não estando tais efeitos, por óbvio, restritos à lavra do petróleo em terra. E ocorrem **não**

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

apenas para os primeiros municípios que recebem o óleo bruto da plataforma continental, como especialmente para aqueles que o armazenam e o processam.

8) Isso tudo é também corroborado por uma atividade de interpretação/concretização do art. 20, § 1º, CF, designadamente através dos elementos de interpretação, aí incluído o âmbito normativo;

9) É cânone da interpretação constitucional a consideração de que **seus termos são utilizados num sentido mais leigo, sem tanta precisão técnica**. É o que também acontece na referência à *exploração* feita pelo § 1º do art. 20 da Constituição. Além disso, como afirma Friedrich Müller, **o conceito jurídico de um termo difere do conceito técnico que ele possui em sua área do conhecimento**. Fosse, aliás, um conceito técnico do ramo do petróleo, a exploração seria o equivalente à mera pesquisa, prévia à atividade de extração. O significado mais adequado ao termo é comum, no sentido de "fazer produzir; desenvolver (um negócio ou indústria); empreender, cultivar". O termo exploração, pois, não significa unicamente a atividade de extração de petróleo e gás, para fins de distribuição dos *royalties*. ***A exploração de petróleo e gás, para fins constitucionais, constitui atividade complexa que se inicia com a pesquisa, passa pela extração, pelas atividades de embarque e desembarque e culmina com o processamento, quando então se transforma em outro produto, pronto para o consumo***;

10) Tanto o elemento literal quanto o teleológico indiciam que, quanto à exploração na plataforma continental, a **atividade passível de compensação é a de suporte logístico para o transporte, armazenamento ou beneficiamento do petróleo**. Corolário disso é que, ***quanto às atividades desenvolvidas na plataforma continental, têm mais legitimidade para o recebimento os municípios portadores de instalações de embarque e desembarque de petróleo e aqueles por elas afetados, do que os meramente confrontantes, chamados também produtores***, que têm relação indireta com a extração;

11) Mesmo que se desse vazão à força do elemento genético de interpretação, e que se entendesse presente o chamado critério do determinismo físico, a

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

aquinhoar os municípios confrontantes pela mera extensão fictícia de suas linhas ao território da plataforma continental em que ocorre a extração de petróleo, ainda assim a noção de prejudicialidade, de impactos ambientais e socioeconômicos, está inserida também nos dispositivos legais que contemplavam os confrontantes, quando menos para a caracterização das áreas geoeconômicas, cujos municípios integrantes também estão aptos ao recebimento de *royalties*. Em outras palavras, caso se entendesse, erroneamente, dever-se tomar como referência os critérios existentes na lei anterior para a compreensão do dispositivo constitucional (pois é sabido que, na Constituição, termos de leis anteriores que inspiraram determinados dispositivos ganham outro significado), mesmo aí está ínsita, a par do determinismo físico, a noção de prejudicialidade para qualquer compreensão que se venha a fazer de municípios portadores de instalações e/ou afetados por operações de embarque e desembarque de petróleo;

12) Porém, em vez de limitar a utilização do critério do determinismo físico para os confrontantes, a ANP subverteu a teleologia dos arts. 48 e 49 (arts. 48, inciso I, alínea "c" e inciso II, alínea "c" e 49, inciso II, alínea "c", da Lei n.º 9.478/97, na redação dada pela Lei n.º 12.734/2012), incrementando esse critério ao exigir uma suposta ligação ao campo produtor – na plataforma continental!!! – da instalação de embarque e desembarque que recebe o petróleo dali oriundo e transportado até a costa brasileira;

13) Estudiosos dos impactos da atividade petrolífera sobre municípios e regiões, Rodrigo Serra e Carla Patrão afirmam restar, "como definição sensível aos efetivos impactos econômicos das atividades petrolíferas sobre o continente, o conceito de municípios onde se localizam instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque vinculados àquela indústria." (grifos nossos);

14) **O art. 20, § 1º, CF, mediante a noção de compensação, corrobora a necessidade de uma indenização em face de um prejuízo sofrido pelos municípios que suportam as atividades de embarque e desembarque de petróleo ou são por elas afetados;**

15) A compensação justifica-se nos seguintes casos: (i) quando a vocação socioeconômica do município se altera em vista da instalação do aparato da

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

indústria do petróleo, com todas as consequências daí advindas; (ii) em função de riscos ou impactos ambientais e/ou paisagísticos; (iii) em vista da essencialidade das instalações localizadas nos municípios, para o adequado escoamento do petróleo e do gás natural, com eventuais riscos ambientais daí advindos. Afora tais situações, são aquinhoados constitucionalmente também os municípios confrontantes;

16) O âmbito normativo revela que a indústria do petróleo é primariamente poluente, portanto de forte impacto ambiental, devendo ser abarcada no regime de cautelas e políticas de prevenção previstos no art. 225 da Constituição. O petróleo e o gás natural, nesse sentido, devem ser considerados também recursos minerais, estando aqueles que os exploram obrigados a recuperar o meio ambiente degradado, nos termos do art. 225, § 2º, CF;

17) O meio ambiente degradado, quando da exploração na plataforma continental, não é somente a área respeitante aos equipamentos situados no mar. O meio ambiente que se degrada é também e fundamentalmente aquele respeitante às áreas em que situados os equipamentos em terra, que acolhem o petróleo oriundo do mar. Essa recuperação é feita em variante do princípio poluidor-pagador, consistente no pagamento de *royalties*;

18) Cabe referir outro elemento do âmbito normativo, crucial para a compreensão dos municípios a serem compensados. Trata-se da complementaridade entre as estruturas e equipamentos existentes para o recebimento do petróleo oriundo da plataforma continental. Com efeito, uma monobóia necessita de um parque de tancagem, e vice-versa; e ambos necessitam, posteriormente, de uma refinaria. Se situados em Municípios diversos, obviamente que devem todos eles receber a devida compensação, na modalidade *royalties*;

19) As hipóteses de interpretação da lei que exigem, para distribuição de *royalties*: a) a ligação direta da instalação ao campo produtor; ou b) maior pertinência à extração do que à distribuição do petróleo, são inconstitucionais, **na medida em que excluem municípios portadores de instalações e/ou afetados, todos sofredores de iguais ou maiores impactos ambientais,**

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

socioeconômicos ou paisagísticos, do direito à compensação. **Esse direito à compensação é norma de índole constitucional**;

20) Além disso, os referidos critérios restritivos são completamente destituídos de razoabilidade e igualdade. Com efeito, como se pode exigir ligação direta a um campo produtor localizado por vezes a dezenas ou a mais de uma centena de quilômetros da plataforma continental? Nesses casos, artificialmente está-se a considerar que a ligação direta faz-se com o "primeiro ponto" de desembarque do óleo. Não há, contudo, razoabilidade nessa consideração. E a igualdade resta violada, na medida em que outros municípios não são compensados como os primeiros que recebem o óleo bruto da plataforma continental;

V – DA MEDIDA CAUTELAR

113. A Constituição Federal e a Lei n.º 9.868/99 autorizam o deferimento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade para suspender a eficácia da lei ou ato normativo impugnado. De outro lado, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal vem admitido a possibilidade excepcional de suspensão de processos, *ex vi* das ADIs n.º 5365 e 5353.

114. Na ADI n.º 5353, o Min. Rel. Roberto Barroso sustenta a ideia de unidade do sistema de controle concentrado de normas pelo Supremo Tribunal Federal, com a consequente possibilidade de aplicação analógica do art. 5º, da Lei n.º 9.882/99 e do art. 21, da Lei n.º 9.868/99, que facultam a suspensão do andamento de processos que envolvam a aplicação da lei ou ato normativo questionado. Vejamos:

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

III. Da possibilidade excepcional de suspensão do andamento de processos

7. A ação direta de inconstitucionalidade, por constituir processo objetivo de fiscalização de constitucionalidade, não se destina à resolução de situações concretas. No entanto, como todas as leis se destinam a produzir consequências no mundo real, não pode ser indiferente ao intérprete situação excepcional e grave que envolva a aplicação do ato impugnado. É esta a hipótese aqui. Está-se diante de decisão judicial potencialmente capaz de gerar situação irreversível, além de afetar o direito fundamental de liberdade.

8. A Lei nº 9.882, de 3.12.1999, que disciplina a arguição de descumprimento de preceito fundamental, prevê, em seu art. 5º, a possibilidade de concessão de medida liminar para a suspensão do andamento de processo ou dos efeitos de decisões judiciais (§ 3º), inclusive monocraticamente, em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave (§ 1º). Da mesma forma, a Lei nº 9.868, de 10.11.1999, contempla, em relação à ação declaratória de constitucionalidade, a suspensão do julgamento de processos que envolvam a aplicação da lei questionada (art. 21).

9. Não existe, é bem de ver, previsão idêntica no tocante à ação direta de inconstitucionalidade. Porém, o Supremo Tribunal Federal tem evoluído, ao longo do tempo, para tratar as ações diretas como uma unidade conceitual. Existe, na verdade, um gênero, que é a ação constitucional, que comporta variações de espécies, em razão de seus requisitos e do seu objeto. Tais ações, no entanto, sujeitam-se a uma disciplina uniforme, no que couber. Por esta razão, afigura-se perfeitamente possível a aplicação analógica da possibilidade de concessão de medida cautelar suspensiva de ações em ação direta de inconstitucionalidade. Não fora por esta razão, a providência estaria legitimada pelo poder geral de cautela do juiz.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

> 10. Deve-se observar, ademais, que mesmo no controle incidental de constitucionalidade, o relator da causa no Supremo Tribunal Federal pode determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria discutida em regime de repercussão geral, conforme previsto no art. 328, in fine , do RI/STF. Não há razão para que o mesmo não possa valer para o controle concentrado. Aliás, existem precedentes do Tribunal nessa linha, como ilustram as ADIs 4.627 e 5.298, de relatoria do Min. Luiz Fux.

115. No caso concreto, a razoabilidade jurídica da tese apresentada já foi suficientemente demonstrada. É juridicamente inadmissível uma interpretação da Lei n.º 9.478/97 (bem como das Leis n.º 12.734/2012 e 12.351/2010) que ignore os condicionamentos normativos dos dispositivos constitucionais apontados ao longo da presente ação. Além disso, não é possível admitir que a ANP (por mais que conduza seu trabalho com esmero e dedicação) esteja livre para agir a seu talante quando do exercício do poder regulamentar, ignorando os condicionamentos legais e constitucionais.

116. De outro lado, o *periculum in mora* e a necessidade de suspensão dos processos que versam sobre os arts. 48 e 49, inciso I, alínea "c" e inciso II, alínea "d", da Lei n.º 9.478/97 (bem como dos arts. 48, inciso I, alínea "c" e inciso II, alínea "c" e 49, inciso II, alínea "c", da Lei n.º 9.478/97, na redação da Lei n.º 12.734/2012) e art. 42-B, inciso I, alínea "c" e inciso II, alínea "c", da Lei n.º 12.351/10, na redação dada pela Lei n.º 12.734/2012, decorre dos possíveis danos em razão da demora na decisão.

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

117. A prevalecer a tese da ANP, inúmeros municípios podem ser privados do seu direito constitucional de percepção dos *royalties* do petróleo. Isso suscitará enorme desequilíbrio federativo, excluindo-se municípios amplamente legitimados, em prol de outros que já recebem generoso quinhão na distribuição dos *royalties*.

118. Muito embora a ADI não se destine à solução de casos concretos, há um cenário de instabilidade jurídica que compromete a segurança jurídica. Os Tribunais pátrios vem atribuindo diferentes interpretações aos dispositivos legais que são objeto da presente ação. O trânsito em julgado dessas decisões gerará reflexos na ordem social, pois repercutirá na capacidade financeira dos municípios concretizarem os direitos fundamentais constitucionais, especialmente aqueles de índole prestacional. O não recebimento dos *royalties* do petróleo reduz o investimento em saúde, educação, assistência social, habitação, etc., com consequências não apenas sobre o orçamento municipal, mas sobre as vidas das pessoas mais carentes.

119. **Tendo em vista a relevância da matéria para a ordem social e para a segurança jurídica, requer, liminarmente, a suspensão do andamento de todos os processos em que se discuta a constitucionalidade dos arts. 48 e 49, inciso I, alínea "c" e inciso II, alínea "d", da Lei n.º 9.478/97 (bem como dos arts. 48, inciso I, alínea "c" e inciso II, alínea "c" e 49, inciso II, alínea "c", da Lei n.º 9.478/97, na redação da Lei n.º 12.734/2012) e do art. 42-B, inciso I, alínea "c" e inciso II, alínea "c", da Lei n.º 12.351/10, na redação dada pela Lei n.º 12.734/2012, até o julgamento definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade.**

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

VI – DOS PEDIDOS

Em face do exposto, requer seja julgada procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, por ofensa ao art. 5º, incisos II e LIV (ofensa ao devido processo legal em sentido substancial); art. 20, § 1º e art. 225 da Constituição Federal, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos arts. 48 e 49, inciso I, alínea "c", e inciso II, alínea "d", da Lei n.º 9.478/97, na redação original; arts. 48, inciso I, alínea "c" e inciso II, alínea "c" e 49, inciso II, alínea "c", da Lei n.º 9.478/97, na redação da Lei n.º 12.734/2012, bem como do art. 42-B, inciso I, alínea "c" e inciso II, alínea "c", da Lei n.º 12.351/10, na redação dada pela Lei n.º 12.734/2012, para que, mediante interpretação conforme a constituição:

a) seja excluída do ordenamento jurídico brasileiro a interpretação que exige, para o recebimento de *royalties* pelos municípios, a ligação direta das instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural ao campo produtor, mormente quando se trata de petróleo oriundo da plataforma continental;

b) seja excluída do ordenamento jurídico brasileiro a interpretação que exige, para o recebimento de *royalties* pelos municípios, sejam as instalações predominantemente voltadas à extração do petróleo, especialmente quando provindo o petróleo da plataforma continental;

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br

c) seja excluída a interpretação de que é permitido à ANP a livre definição dos critérios de afecção, bem como do que sejam operações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural.

Requer sejam requisitadas informações ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional e ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, no prazo de 30 dias, contados do recebimento, nos termos do art. 6º da Lei n.º 9.868/99.

Requer, por fim, seja ouvido o Procurador-Geral da República, nos termos do art. 103, § 1º, da Constituição Federal, bem como a citação do Advogado-Geral da União, *ex vi* do art. 103, § 3º, da Constituição Federal, para que se manifestem sobre o feito.

Protesta por todos os meios de prova compatíveis com o processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade, e dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nestes termos, pede deferimento.
Brasília, 09 de novembro de 2016.

Rodrigo Meyer Bornholdt
OAB/SC 10.292

Nestor Castilho Gomes
OAB/SC 21.175

João Fábio Silva da Fontoura
OAB/SC 26.510

Rua Orestes Guimarães, 876 - 6º andar - América - CEP 89204-060 - Joinville - SC
Fone: 47 3451-5700 - Fax: 47 3451-5701 - www.bh.adv.br